EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9)
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
REL. P/ ACÓRDÃO : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
EMBARGANTE : PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS : FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539
ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO : BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS : TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227
CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494
ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao *dobro* do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de e*ngano justificável*" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

ENTENDIMENTO DA EMINENTE MINISTRA RELATORA

3. Em seu judicioso Voto, a eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, lúcida e brilhante como sempre, consignou que o entendimento das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do STJ é o de que "a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor". Destacou que os arestos indicados como paradigmas "firmam ser suficiente para que haja a devolução em dobro do indébito a verificação da culpa."

4. A solução do dissídio, como antevê a eminente Relatora, pressupõe seja definido o que se deve entender, no art. 42, parágrafo único, pelo termo "engano justificável". Observa ela, corretamente, que "a

conclusão de que a expressão 'salvo hipótese de engano justificável' significa 'comprovação de má-fé do credor' *diminui o alcance* do texto legal em prejuízo do consumidor, *parte vulnerável* na relação de consumo" (grifo acrescentado). Dessa forma, dá provimento aos Embargos de Divergência, pois, "ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, não é necessária a comprovação da má-fé do credor, basta a culpa."

5. Por não haver óbices processuais, irreparável a compreensão da eminente Relatoria original quanto ao conhecimento do recurso.

6. A Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com precisão cirúrgica, aponta dois pressupostos fundamentais do modelo hermenêutico que rege a aplicação do CDC: a) vedação à interpretação e à analogia que diminuam "o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor" e b) valorização ético-legislativa da "parte vulnerável na relação de consumo".

DIVERGÊNCIA ENTRE A PRIMEIRA SEÇÃO (DIREITO PÚBLICO) E A SEGUNDA SEÇÃO (DIREITO PRIVADO) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

7. Para fins de Embargos de Divergência – resolver teses jurídicas divergentes dentro do STJ –, estamos realmente diante de entendimentos discrepantes entre a Primeira e a Segunda Seções no que tange à aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, dispositivo que incide sobre todas as relações de consumo, privadas ou públicas, individuais ou coletivas.

8. “Conhecidos os embargos de divergência, a decisão a ser adotada não se restringe às teses suscitadas nos arestos em confronto – recorrido e paradigma –, sendo possível aplicar-se uma terceira tese, pois cabe a Seção ou Corte aplicar o direito à espécie” (EREsp 513.608/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.11.2008). No mesmo sentido: “O exame dos embargos de divergência não se restringe às teses em confronto do acórdão embargado e do acórdão paradigma acerca da questão federal controvertida, podendo ser adotada uma terceira posição, caso prevalente” (EREsp 475.566/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 13/9/2004). Outros precedentes: EREsp 130.605/DF, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, DJ 23/4/2001; e AgRg nos EREsp 901.919/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 21/9/2010.

HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC

9. Em harmonia com os ditames maiores do Estado Social de Direito, na tutela de sujeitos vulneráveis, assim como de bens, interesses e direitos supraindividuais, ao administrador e ao juiz incumbe exercitar o *diálogo das fontes*, de modo a – fieis ao espírito, *ratio* e princípios do microssistema ou da norma – realizarem material e não apenas formalmente os objetivos cogentes, mesmo que implícitos, abonados pelo texto legal. Logo, interpretação e integração de preceitos legais e regulamentares de proteção do consumidor, codificados ou não,

submetem-se a *postulado hermenêutico de ordem pública* segundo o qual, em caso de dúvida ou lacuna, o entendimento administrativo e o judicial devem expressar o posicionamento mais favorável à real superação da vulnerabilidade ou mais condutivo à tutela efetiva dos bens, interesses e direitos em questão. Em síntese, não pode "ser aceita interpretação que contradiga as diretrizes do próprio Código, baseado nos princípios do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação de sua defesa em juízo" (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011). Na mesma linha da interpretação favorável ao consumidor: AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 26/2/2016; REsp 1.726.225/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/9/2018; e REsp 1.106.827/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/10/2012. Confira-se também: "O mandamento constitucional de proteção do consumidor deve ser cumprido por todo o sistema jurídico, em diálogo de fontes, e não somente por intermédio do CDC" (REsp 1.009.591/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/8/2010).

10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do *princípio da vulnerabilidade* e do *princípio da boa-fé objetiva*, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a *engano* e nega a devolução em dobro somente se for ele *justificável*. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a *justificabilidade* (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no *domínio da causalidade*, e não no *domínio da culpabilidade*, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva.

11. Na hipótese dos autos, necessário, **para fins de parcial modulação temporal de efeitos**, fazer distinção entre *contratos de serviços públicos* e *contratos estritamente privados*, sem intervenção do Estado ou de concessionárias.

REPOSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR PARA O ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA

12. Ao apresentar a tese a seguir exposta, esclarece-se que o Relator para o acórdão reposiciona-se a respeito dos critérios do parágrafo único do art. 42 do CDC, de modo a reconhecer que **a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a *boa-fé objetiva do fornecedor* na cobrança realizada**. É adotada, pois, a posição que se formou na Corte Especial, lastreada no princípio da boa-fé objetiva e consequente descasamento de elemento volitivo, consoante Voto-Vista do **Ministro Luis Felipe Salomão** e manifestações apresentadas pelos eminentes Pares, na esteira de intensos e ricos debates nas várias sessões em que o tema foi analisado. Realça-se, quanto a esses últimos, trecho do Voto do **Ministro Og Fernandes**: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) *independe da natureza do elemento volitivo* do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar

conduta contrária à boa-fé objetiva".

CONTRATOS QUE ENVOLVAM O ESTADO OU SUAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

13. Na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve prevalecer o **princípio da boa-fé objetiva**, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.

14. A esse respeito, o entendimento prevalente nas Turmas da Primeira Seção do STJ é o de dispensar a exigência de dolo, posição sem dúvida inspirada na preeminência e inafastabilidade do *princípio da vulnerabilidade do consumidor* e do *princípio da boa-fé objetiva*. A propósito: REsp 1.085.947/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 12/11/2008; AgRg no REsp 1.363.177/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/5/2013; REsp 1.300.032/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.307.666/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/3/2013; AgRg no REsp 1.376.770/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; AgRg no REsp 1.516.814/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/8/2015; AgRg no REsp 1.158.038/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/5/2010; AgInt no REsp 1.605.448/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/12/2017; AgRg no AgRg no AREsp 550.660/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/12/2015; AgRg no AREsp 723.170/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; AgRg no Ag 1.400.388/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2014.

15. Na Segunda Seção há também precedente que rechaça o requisito do dolo para repetição do indébito em dobro: "Somente na presença de má-fé ou culpa o pagamento em dobro é devido" (AgRg no AREsp 162.232/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.8.2013).

16. Agrega-se ao raciocínio construído na Primeira Seção a regra geral de que a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é *objetiva* em relação a danos causados a terceiros (art. 37, § 6º, da CF/1988). Cito precedentes do STJ sobre o tema: REsp 1.299.900/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/3/2015; AgInt no REsp 1.581.961/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2016; AgInt no REsp 1.711.214/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2020; REsp 1.736.039/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7/6/2018; AgInt no AREsp 1.238.182/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/9/2018; AgInt no AREsp 937.384/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/6/2018; REsp 1.268.743/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 7/4/2014; REsp 1.038.259/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/2/2018.

17. Quanto ao art. 37, § 6º, da Carta Magna, o Supremo Tribunal

Federal sedimentou, sob o rito da Repercussão Geral, a posição de que "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (RE 591.874, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 26.8.2009, Repercussão Geral – Mérito, DJe 18.12.2009). Na mesma linha: ARE 1.043.232 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/9/2017; RE 598.356, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º/8/2018; ARE 1.046.474 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12/9/2017; e ARE 886.570 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2017.

18. Ora, se a regra da responsabilidade civil objetiva impera, universalmente, em prestações de serviço público, como admitir que, nas relações de consumo – na presença de sujeito (consumidor) caracterizado *ope legis* como vulnerável (CDC, art. 4º, I) –, o paradigma jurídico seja o da responsabilidade subjetiva (com dolo ou culpa)? Seria contrassenso atribuir tal privilégio ao fornecedor, mormente por ser fato notório que dezenas de milhões dos destinatários finais dos serviços públicos, afligidos por cobranças indevidas, personificam não só sujeitos vulneráveis, como também sujeitos indefesos e hipossuficientes econômica e juridicamente, ou seja, carentes em sentido lato, destituídos de meios financeiros, de informação e de acesso à justiça.

19. Compreensão distinta, centrada na necessidade de prova de elemento volitivo, na realidade inviabiliza a devolução em dobro, p. ex., de pacotes de serviços telefônicos jamais solicitados pelo consumidor, bastando ao fornecedor invocar uma justificativa qualquer para seu engano. Nas condições do mercado de consumo massificado, impingir ao consumidor prova de dolo ou culpa corresponde a castigá-lo com ônus incompatível com os princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, legitimando, ao contrário dos cânones do microssistema, verdadeira *prova diabólica*, o que contraria frontalmente a filosofia e *ratio* eticossocial do CDC. Assim, a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como *elemento de causalidade*, e não como *elemento de culpabilidade*.

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

20. Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários, de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção. Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, *sem*

necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

21. Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que **a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a *boa-fé objetiva do fornecedor* na cobrança realizada**. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

22. A proposta aqui trazida – que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos **Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO** – consiste em **reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta** (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a **boa-fé objetiva do fornecedor** (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

23. Registram-se trechos dos Votos proferidos que contribuíram diretamente ou serviram de inspiração para a posição aqui adotada (grifos acrescentados):

23.1. **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**: "O requisito da comprovação da má-fé não consta do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem em qualquer outro dispositivo da legislação consumerista. A parte final da mencionada regra – 'salvo hipótese de engano justificável' – não pode ser compreendida como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor."

23.2. **MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**: "Os requisitos legais para a repetição em dobro na relação de consumo são a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável do fornecedor. *A exigência de indícios mínimos de má-fé objetiva do fornecedor é requisito não previsto na lei e, a toda evidência, prejudica a parte frágil da relação.*"

23.3. **MINISTRO OG FERNANDES**: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) *independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.*"

23.4. **MINISTRO RAUL ARAÚJO**: "Para a aplicação da sanção civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de *conduta contrária à boa-fé objetiva* para justificar a reprimenda civil de imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente."

23.5. **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**: "O código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar *a concepção objetiva* do abuso do direito, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, *prescindindo da verificação da intenção do agente – dolo ou culpa* – para caracterização de uma conduta como abusiva (...) Não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, *objetivamente*, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável."

24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia: **a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.**

PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL
DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO

25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva **modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão**.

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: **A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.**

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se **MODULAR OS EFEITOS** da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos *não* decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o *acórdão recorrido* fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: "Prosseguindo no julgamento, após o voto do Sr. Ministro Herman Benjamin conhecendo dos embargos de divergência e dando-lhes provimento, com modulação dos efeitos, no que foi acompanhado pelos Srs. Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo e Humberto Martins, e a ratificação dos votos das Sras. Ministras Relatora e Nancy Andrighi, a Corte Especial, por maioria, conheceu dos embargos de divergência e deu-lhes provimento, com modulação dos efeitos.

Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Herman Benjamin. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Herman Benjamin. Vencidas as Sras. Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura que conheciam dos embargos e davam-lhes provimento, mas por outro fundamento e sem modulação dos efeitos.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, João Otávio de Noronha e Napoleão Nunes Maia Filho.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz."

Brasília, 21 de outubro de 2020(data do julgamento)..

MINISTRA LAURITA VAZ
Presidente

MINISTRO HERMAN BENJAMIN
Relator

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**
EMBARGANTE	:	PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539 ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO	:	BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS	:	TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227 CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494 ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA:

Trata-se de embargos de divergência interpostos por Pedro Lugoch contra acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte assim ementado:

> AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
>
> 1. A repetição de indébito em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor não prescinde da prova de má-fé do credor. Incidência da Súmula 83/STJ.
>
> 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

Alega o embargante dissídio jurisprudencial no tocante ao tema relativo à repetição do indébito em dobro, disciplinado no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, apontando como paradigmas julgados da Primeira e Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 371.431/MS e AgRg no AREsp 262.212/RS, respectivamente).

Afirma que há divergência quanto à necessidade de comprovação da má-fé na cobrança indevida para que a devolução se dê em dobro.

Confiram-se as ementas dos precedentes trazidos a confronto:

> ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 182/STJ. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. PRAZOS GERAIS DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO FIXADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 412/STJ.
>
> (...)
>
> 2. O STJ firmou o entendimento de que basta a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente

pelo consumidor na cobrança indevida de serviços públicos concedidos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 143.622/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.6.2012; AgRg no Ag 1.417.605/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 2.2.2012; AgRg no Resp 1.117.014/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.2.2010; e REsp 1.085.947/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 12.11.2008.

(...)

6. Agravo Regimental conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(AgRg no ARESp 262.212/RS, Relator o Ministro Herman Benjamin, DJe de 07/03/2013)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO AO ART. 42 DO CDC. SÚMULA 7/STJ.

1. "O STJ firmou o entendimento de que basta a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor na cobrança indevida de serviços públicos concedidos" (**AgRg no AREsp 262.212/RS**, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2013).

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 371.431/MS, Relator o Ministro Sérgio Kukina, DJe de 22/10/2013)

Admitido o recurso, não houve impugnação, conforme certificado pela Coordenadoria da Corte Especial à fl. 667.

É o relatório.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9)
EMENTA

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Para que haja a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é desnecessária a comprovação da má-fé do credor, bastando a culpa.
2. Embargos de divergência providos.

VOTO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora):

Senhora Presidente, essa questão tem sido trazida amiúde a essa Corte, daí porque peço licença para apresentar meu voto neste caso, trazendo os mesmos fundamentos já utilizados quando do meu voto no Earesp 600.663/SP.

Dispõe o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor:

> Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
> Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O acórdão embargado reflete o entendimento das Terceira e Quarta Turmas desta Corte no sentido de que a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor. Ao ensejo, veja-se o seguinte trecho do aresto:

> Com efeito, é de se observar que o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual se orienta no sentido de que "a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do credor" (AgRg no REsp 848.916/PR, Rei. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 14.10.2011).
> Confiram-se, ainda:
> (...)

> No caso em exame, não estando caracterizada a má-fé da recorrente em cobrar os valores do recorrido, deve ser afastado o dever de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
>
> Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados do recorrido.

Os julgados paradigmas, de outro lado, firmam ser suficiente para que haja a devolução em dobro do indébito a verificação da culpa. A propósito, confira-se:

> O STJ firmou o entendimento de que basta a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor na cobrança indevida de serviços públicos concedidos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 143.622/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.6.2012; AgRg no Ag 1.417.605/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 2.2.2012; AgRg no Resp 1.117.014/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.2.2010; e REsp 1.085.947/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 12.11.2008.

Vale dizer, enquanto as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte entendem que basta a culpa para a devolução em dobro, as Turmas de Direito Privado acentuam que mister a comprovação da má-fé do credor na cobrança indevida.

Tal distinção já foi, inclusive, abordada por Leonardo de Medeiros Garcia, na obra Direito do Consumidor, Código Comentado e Jurisprudência, 8ª edição, 2012, Editora Impetus, p. 319/321, *verbis*:

> Para a aferição do "engano justificável" é preciso analisar se não houve culpa por parte do fornecedor. Se ele provar que não houve negligência, imprudência ou imperícia de sua parte, ficará isento de indenizar o consumidor pelo dobro da quantia cobrada. Seria o caso de uma cobrança indevida em razão de um vírus do computador que alterou o valor a ser exigido do consumidor ou o erro cometido pelos correios quando da entrega do boleto de pagamento. Entretanto, o fornecedor não poderá se eximir alegando que o erro foi praticado por um funcionário seu, uma vez que responde pelos atos causados pelos seus subordinados.
>
> No mesmo sentido, a 1ª Seção do STJ (composta pelas 1ª e 2ª Turmas), responsável pelos julgamentos envolvendo serviços públicos, exige a "culpa" do fornecedor para a devolução em dobro.
>
> > RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. ENQUADRAMENTO NO REGIME DE ECONOMIAS. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o *consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e*

> *juros legais, salvo hipótese de engano justificável"*. 2. Interpretando o referido dispositivo legal, as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte de Justiça firmaram orientação no sentido de que "*o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço*" (REsp 1.079.064/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 20.4.2009). Ademais, "*basta a culpa para a incidência de referido dispositivo, que só é afastado mediante a ocorrência de engano justificável por parte do fornecedor*" (REsp 1.085.947/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.11.2008). Destarte, o engano somente é considerado justificável quando não decorrer de dolo ou culpa. 3. Na hipótese dos autos, conforme premissas fáticas formadas nas instâncias ordinárias, não é razoável falar em engano justificável. A cobrança indevida de tarifa de água e esgoto deu-se em virtude de culpa da concessionária, a qual incorreu em erro no cadastramento das unidades submetidas ao regime de economias. Assim, caracterizada a cobrança abusiva, é devida a repetição de indébito em dobro ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. (STJ, REsp. 1084815/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 05/08/2009)

> Mas, a 2ª Seção (composta pelas 3ª e 4ª Turmas), responsável pelos julgamentos de Direito Privado (com exceção das ações envolvendo serviços públicos que, como vimos, é competência da 1ª Seção), exige que o fornecedor tenha agido com má-fé, não sendo suficiente somente a verificação da culpa, dificultando o ressarcimento do dobro do que pagou em excesso pelo consumidor.
>
> > O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé (STJ, AgRg no Ag 570214/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28/06/2004)
>
> (...)
>
> Concluindo, para que haja a devolução em dobro, nos moldes do parágrafo único do art. 42, o STJ tem entendido que:
>
> - nos casos envolvendo serviços públicos, basta a verificação de culpa - entendimento da 1ª Seção do STJ;
>
> - nos demais casos, tem que haver a má-fé do fornecedor na cobrança indevida - entendimento da 2ª Seção do STJ;

Nesse passo, cumpre definir quais são os critérios para a devolução em dobro do indébito.

Da letra da lei extrai-se que a repetição em dobro depende da cobrança indevida, do pagamento em excesso, bem como da inexistência de engano justificável do fornecedor/credor.

E o que seria o engano justificável? Com a devida vênia, acompanho a lição do Ministro Herman Benjamin, quando do exame do REsp 1079064/SP, Segunda Turma, julgado em 02/04/2009, DJe de 20/04/2009, no sentido de que "o engano é justificável exatamente quando não decorre de dolo ou de culpa" (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor:

comentado pelos autores do anteprojeto, 9ª ed., Rio de janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 408).

Ou seja, ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, não é necessária a comprovação da má-fé do credor, basta a culpa.

A meu sentir, a conclusão de que a expressão "salvo hipótese de engano justificável" significa "comprovação da má-fé do credor" diminui o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo.

Nesse contexto, penso que deve prevalecer a orientação das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte quanto ao tema.

No caso concreto, asseverou o Tribunal local a inexigência de comprovação da existência de má-fé do consumidor para haver a restituição em dobro das parcelas indevidamente pagas, tendo o acórdão ora embargado dado parcial provimento ao recurso especial da empresa de telefonia para afastar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência para negar provimento ao recurso especial da empresa de telefonia.

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2013/0355826-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EREsp 1.413.542 / RS**

Números Origem: 00024664120118210124 00382183920138217000 11100012910 12111794201382170000 12411100012910 24664120118210124 382183920138217000 70052756772 70053135935 70053964904

PAUTA: 02/05/2018 JULGADO: 02/05/2018

Relatora
Exma. Sra. Ministra **MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE	:	PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539 ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO	:	BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS	:	TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227 CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494 ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por Dano Moral

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentou oralmente o Dr. Bruno Di Marino, pelo embargado.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto da Sra. Ministra Relatora conhecendo dos embargos de divergência e dando-lhes provimento, pediu vista o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Aguardam os Srs. Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Felix Fischer, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Napoleão Nunes Maia Filho.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2013/0355826-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EREsp 1.413.542 / RS**

Números Origem: 00024664120118210124 00382183920138217000 11100012910 12111794201382170000 12411100012910 24664120118210124 382183920138217000 70052756772 70053135935 70053964904

PAUTA: 05/12/2018 JULGADO: 18/12/2018

Relatora
Exma. Sra. Ministra **MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE	:	PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539 ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO	:	BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS	:	TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227 CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494 ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por Dano Moral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento para a sessão do dia 1º de fevereiro de 2019.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2013/0355826-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EREsp 1.413.542 / RS**

Números Origem: 00024664120118210124 00382183920138217000 11100012910 12111794201382170000 12411100012910 24664120118210124 382183920138217000 70052756772 70053135935 70053964904

PAUTA: 05/12/2018 JULGADO: 01/02/2019

Relatora
Exma. Sra. Ministra **MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE	:	PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539 ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO	:	BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS	:	TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227 CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494 ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por Dano Moral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento para a próxima sessão.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9)
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE : PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS : FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539
ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO : BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS : TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227
CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494
ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN:

1. Histórico da demanda

Trata-se de Embargos de Divergência, da relatoria da eminente Ministra **Maria Thereza de Assis Moura**, interpostos contra acórdão da Quarta Turma assim ementado:

> AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
> 1. A repetição de indébito em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor não prescinde da prova de má-fé do credor. Incidência da Súmula 83/STJ.
> 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

No Recurso, o embargante sustenta a existência de dissídio com a jurisprudência da Seção de Direito Público do STJ no que se refere à interpretação do art. 42 do CDC. Afirma que a melhor exegese é a que afasta a repetição em dobro somente quando a fornecedora comprova erro escusável, sendo, portanto, desnecessária a prova, pelo consumidor, da má-fé da parte adversa. Cita dissídio com acórdãos da Primeira Turma (AgRg no AREsp 371.431/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 22.10.2013) e da Segunda Turma do STJ (AgRg no AREsp 262.212/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 7.3.2013).

Não foi apresentada impugnação (fl. 667, e-STJ).

A eminente Ministra **Maria Thereza de Assis Moura**, em sessão da Corte Especial, apresentou Voto no qual reconheceu a existência de dissídio. No mérito, reputa que somente o engano justificável exclui a devolução em dobro das quantias indevidamente recebidas. Define como conceito de "engano justificável" aquele adotado no exame do REsp 1.079.064/SP (Segunda Turma do STJ, Relator Ministro Herman Benjamin), ou seja, o "que não decorre de dolo ou culpa". Acrescenta que, a seu ver, "a conclusão de que a expressão 'salvo hipótese de engano justificável' significa 'comprovação de má-fé do credor' diminui o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo".

Pedi vista dos autos.

2. Desnecessidade da intervenção do Ministério Público como *custos legis*

Nos termos do art. 266-D do RI-STJ, "o Ministério Público, quando necessário seu pronunciamento sobre os embargos de divergência, terá vista dos autos por vinte dias."

Conclui-se que a "necessidade" do pronunciamento do Ministério Público se amolda às hipóteses em que é obrigatória a intervenção, por imposição legal, do *Parquet* como fiscal da ordem jurídica, ou no caso de o relator entender útil a opinião do órgão ministerial.

Embora seja de todo conveniente ouvir o Ministério Público em todos os casos de Recursos Repetitivos, por conta da sua natureza paranormativa, na hipótese dos autos não há elemento que torne obrigatória sua intervenção, consoante o art. 178 do CPC/2015, o que resulta na regularidade do procedimento adotado.

3. Conhecimento

Diante da divergência aberta pelo eminente Ministro **João Otávio de Noronha** quanto ao próprio conhecimento do presente recurso, analiso, em primeiro lugar, exatamente

esse aspecto.

3.1 Embargos de Divergência e as Súmulas 83 e 315/STJ

A primeira objeção à admissibilidade dos Embargos de Divergência, mencionada no Voto do Ministro **João Otávio de Noronha**, diz respeito ao enunciado da Súmula 315/STJ, segundo o qual "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial."

A leitura dos precedentes que justificaram a edição do enunciado dessa súmula, julgado na sessão da Corte Especial realizada em 5.10.2005, evidencia que se objetivou adstringir o cabimento desta espécie recursal às hipóteses em que o **mérito** da pretensão veiculada em Recurso Especial fosse apreciado por uma das seguintes formas: a) diretamente (Recurso Especial julgado originalmente por decisão colegiada); b) em decisão monocrática proferida no próprio apelo nobre, com base no art. 557, § 1º-A, do CPC, e julgada posteriormente em Agravo Regimental (Súmula 316/STJ); ou c) na decisão colegiada que examinasse o Agravo Regimental interposto contra decisão que decidiu o Agravo com base no art. 544, § 3º, do CPC, na redação da Lei 9.756/1998. Transcrevo o seguinte precedente:

> PETIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 266, CAPUT, DO RISTJ, E 546, I, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. HIPÓTESE DIVERSA DA EXCEÇÃO QUE SE FAZ QUANDO O RELATOR JULGA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA, O PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL (ART. 544, § 3º, PRIMEIRA PARTE, E ART. 557, AMBOS DO CPC).
>
> 1. Em regra, não cabem embargos de divergência contra decisões em agravo regimental, porquanto o acórdão a ser embargado há de ter sido proferido em sede de recurso especial, conforme o disposto no art. 266, caput, do RISTJ, e no art. 546, inciso I, do CPC.
>
> 2. A regra, porém, comporta duas exceções, quais sejam, (i) quando o Relator, ao apreciar o agravo de instrumento, julga o mérito do recurso especial, com fundamento no art. 544, § 3º, primeira parte, do CPC; (ii) ou quando o mérito do recurso especial é apreciado pelo Relator em decisão monocrática, com arrimo no art. 557 do CPC. Nesses casos, o acórdão que julgar o agravo regimental eventualmente interposto poderá ser objurgado via embargos de divergência, desde que, é claro, atendidos os pressupostos do recurso.
>
> 3. Embargos de Divergência não conhecidos.
>
> (Pet 2.169/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA

SEÇÃO, DJ 22/3/2004, p. 193).

Verifica-se, nas condições acima, que a Corte Especial entendeu ser pressuposto indispensável para justificar o cabimento dos Embargos de Divergência que o acórdão embargado tenha apreciado o próprio Recurso Especial.

Sucede que a legislação processual sofreu modificações. A redação do art. 544 do CPC/1973 foi posteriormente modificada pela Lei 12.322/2010, nos seguintes termos:

> Art. 544. (...)
> § 4º No Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do agravo obedecerá ao disposto no respectivo regimento interno, podendo o relator:
> I - não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada;
> II - conhecer do agravo para:
> a) negar-lhe provimento, se correta a decisão que não admitiu o recurso;
> b) negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal;
> c) dar provimento ao recurso, se o acórdão recorrido estiver em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal.

Essa modificação é relevante porque, com as alterações legislativas, desburocratizou-se o trâmite processual e, assim, o Agravo passou a ser interposto por simples petição nos autos, e não mais por instrumento. Além disso, *tornou-se possível julgar diretamente a pretensão veiculada no Recurso Especial* (hipóteses do art. 544, § 4º, II, "c").

É por esse motivo, aliás, que os EAg 1.186.352/DF, reportados no voto do eminente Ministro **João Otávio de Noronha**, não se revelam aptos a fundamentar a rejeição dos Embargos de Divergência, com todas as vênias.

Embora matéria praticamente idêntica tenha sido debatida naqueles autos, a verdade é que não se examinou o tema à luz das modificações introduzidas pela Lei 12.322/2010, e sim com base na redação dada ao art. 544 do CPC/1973 pela Lei

9.756/1998.

Na situação em tela, registro que o Agravo foi interposto em 14.2.2014 (fl. 406, e-STJ), ou seja, na vigência da redação do art. 544 do CPC/1973 dada pela Lei 12.322/2010.

Nesse contexto, quer me parecer que a aplicação da Súmula 315/STJ deve ser reexaminada pelo prisma das alterações acima mencionadas. Tendo em vista que o mérito do Recurso Especial pode, no respectivo período de vigência, ser utilizado como fundamento para as instâncias locais negarem a respectiva admissibilidade e, na sequência, para o Superior Tribunal de Justiça processar e julgar o Agravo na forma do art. 544, § 4º, II, "c", do CPC/1973, a simples rejeição dos Embargos de Divergência fulcrada nos termos do óbice da aludida súmula estará equivocada na hipótese específica em que, independentemente da terminologia empregada, houver julgamento do próprio Recurso Especial, ainda que não tenha sido efetuada a conversão do Agravo (art. 544, § 4º, II, "c", do CPC/1973).

No caso concreto, a decisão monocrática, ratificada no acórdão proferido no Agravo Regimental, *analisou a questão de fundo veiculada no Recurso Especial como fundamento para negar provimento ao Agravo*, ao consignar que, "com relação à devolução dos valores cobrados, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a restituição em dobro somente ocorrerá nos casos em que, além de demonstrado o pagamento indevido, ficar comprovada a má-fé do credor" (fl. 517, e-STJ).

Não obstante a letra fria da lei, o fato posto nos autos é que o acórdão embargado invocou tese meritória para não prover o Agravo em Recurso Especial, o que considero suficiente para autorizar a utilização do citado julgamento para configuração de dissídio jurisprudencial dentro do STJ, o que leva à admissibilidade dos Embargos de Divergência.

Sob ponto de vista pragmático e finalístico, o acórdão embargado valeu-se da mencionada tese de mérito, contra a qual, posteriormente, constatou-se dissidência dentro desta Corte Superior, o que entendo não possa ser desconsiderado, *data venia*, para abertura da via dos Embargos de Divergência como instrumento materializador da segurança jurídica e

da efetividade das decisões judiciais.

Esse mesmo raciocínio serve para aplicar a Súmula 83/STJ, de forma que o julgamento embasado em tal enunciado possa também abrir a via dos Embargos de Divergência.

Destaco trecho esclarecedor do Voto-Vista exarado pelo eminente Ministro **Og Fernandes** no julgamento dos EREsp 676.608/RS, em que tratou da mesma questão:

> Enfim, não se tem, aqui, superação de divergência, fundamento essencial para a formulação e, por conseguinte, para a aplicação da Súmula 83/STJ. Ao contrário, o que se tem, no caso, é a configuração de uma divergência frontal entre julgados desta Corte Superior: um aresto que reafirma precedente da Segunda Seção e um paradigma oriundo da Corte Especial, em sentido contrário.
>
> Frise-se, porque oportuno, que chega a estranhar que um enunciado sumular, que foi editado para prestigiar a jurisprudência consolidada desta Casa, sirva, mesmo que por via oblíqua, para obstar que uma divergência seja sanada e que prevaleça a orientação jurisprudencial do Órgão interno deste STJ a quem compete superar as divergências estabelecidas entre as suas demais unidades julgadoras.
>
> Aliás, a se admitir o entendimento – pelo não conhecimento dos Embargos de Divergência – esta Corte Especial estará homologando a seguinte situação: um órgão fracionário deste STJ (Turma ou Seção) aplica a um seu julgamento precedente superado, invoca o disposto na Súmula 83/STJ e, com isso, mesmo que esse "precedente" colida com entendimento recente, inclusive, da própria Corte Especial, estará obstado o conhecimento da divergência.

Para fins de Ação Rescisória, todavia, a questão é de *competência*, e o simples desprovimento do Agravo em Recurso Especial com apoio na Súmula 83/STJ não pode atrair a competência do STJ para o julgamento da ação, que foi detidamente decidida, no mérito, pela Corte de origem, esta sim a competente.

O *discrimen* importante que vejo nas duas situações é que, nos Embargos de Divergência, o foco é a uniformização da jurisprudência, que não pode ser desconsiderada pelo STJ quando um acórdão, mesmo que negando provimento a Agravo em Recurso Especial, invoca tese de mérito do próprio STJ que posteriormente configure o dissídio interpretativo em Embargos de Divergência.

Já na Ação Rescisória a interpretação envolve a competência para julgamento da ação, que deve ser definida com amparo no juízo que adentrou material e formalmente o exame do mérito, o que, na presente hipótese, não atrairia, em tese, a competência do STJ.

Assim, afasto, com a devida vênia, os referidos óbices de conhecimento dos Embargos de Divergência.

3.2. Configuração da divergência de teses

De fato, constato que há divergência jurisprudencial entre a Primeira e a Segunda Seções na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC (grifei):

> Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
>
> Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, *salvo hipótese de engano justificável*.

A Primeira Seção compreende que a repetição de indébito deve ser dobrada em caso de culpa do fornecedor de serviços públicos concedidos:

> PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CULPA OU MÁ-FÉ. ENGANO JUSTIFICÁVEL. PRECEDENTES.
>
> 1. A controvérsia dos autos cinge-se à aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (restituição em dobro). O escopo do mencionado artigo é evitar a inclusão de cláusulas abusivas e nulas que permitam que o fornecedor de produtos e serviços se utilize de métodos constrangedores de cobrança.
>
> 2. Na hipótese dos autos, a cobrança indevida se deu em razão de interpretação equivocada de legislação estadual (Decreto estadual n. 21.123/83), com o consequente enquadramento incorreto da entidade recorrente, o que, nos termos dos mais recentes precedentes desta Corte, afasta a atração do referido artigo.
>
> 3. Caracterizado engano justificável na espécie, notadamente porque o Tribunal de origem, apreciando o conjunto fático-probatório, não constatou a presença de culpa ou má-fé, é de se afastar a repetição em dobro.
>
> 4. Precedentes: REsp 1.099.680/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29.3.2011; AgRg no REsp 1.105.682/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.2.2011; AgRg no REsp 1.151.496/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.
>
> Embargos de divergência improvidos.

(EREsp 1155827/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 30/6/2011).

Já a Segunda Seção exige, para a devolução em dobro, que a cobrança indevida tenha sido feita com dolo:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - CIVIL E CONSUMIDOR - AÇÃO DE COBRANÇA - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO - PRIVATIZAÇÃO DA COPESUL - AQUISIÇÃO DE AÇÕES - MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO - VALORES COBRADOS A MAIOR - RESSARCIMENTO EM DOBRO - CABIMENTO - MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS.

1. Litigância de má-fé. Ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e aquele apontado como paradigma (REsp n. 323.266-SP).

2. Incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado acerca da viabilidade da repetição em dobro de valores nos casos em que comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida.

A cobrança indevida caracterizou-se pela conduta da casa bancária de exigir dos mutuários, no bojo de contrato de mútuo, quantia superior à efetivamente utilizada para a aquisição das ações, diferença que passou a existir em decorrência de deságio sofrido pelas moedas da privatização.

Não integra o conceito de engano justificável a conduta da embargante que, na condição de instituição financeira mandatária, constituída por consumidor para a realização de negócio jurídico de aquisição de ações, descumpre cláusula expressa da avença e, mesmo após reiteradas solicitações dos mandantes para a prestação de contas, atinente à comprovação do valor pago pelas moedas da privatização, recusa-se ao cumprimento da obrigação. Má-fé caracterizada, devendo haver a devolução em dobro das quantias indevidamente exigidas.

3. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, na extensão, desprovidos.

(EREsp 1127721/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/3/2013).

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESOLUÇÃO STJ N. 12/2009. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR.

1. A Corte Especial, apreciando questão de ordem levantada na

> Rcl 3752/GO, em atenção ao decidido nos EDcl no RE 571.572/BA (relatora a Min. ELLEN GRACIE), entendeu pela possibilidade de se ajuizar reclamação perante esta Corte com a finalidade de adequar as decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais estaduais à súmula ou jurisprudência dominante do STJ, de modo a evitar a manutenção de decisões conflitantes a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional no âmbito do Judiciário.
>
> 2. A egrégia Segunda Seção desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não prescinde da demonstração da má-fé do credor.
>
> 3. Reclamação procedente.
>
> (Rcl 4.892/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 11/5/2011).

Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Quarta Turma asseverando que "a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor do serviço"; por sua vez, os acórdãos paradigmas, da Primeira Seção, afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa.

Em primeiro lugar, não vejo como relevante a diferença entre as relações jurídicas específicas apreciadas pela Primeira Seção (cobrança de consumidor por serviços públicos concedidos mediante tarifa) e as examinadas pela Segunda Seção (contratos bancários) a ponto de descaracterizar a similitude fática entre os entendimentos, pois essa peculiaridade não prejudica a semelhança *latu sensu* (= relação de consumo), esta sim apta a gerar o liame comum entre os casos de interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Sobre esse ponto, não posso deixar de destacar as percucientes ponderações da eminente Ministra **Maria Thereza de Assis Moura** durante sessão da Corte Especial no julgamento dos EAREsp 622.897/RS:

> (...) a Corte tem que decidir qual é a interpretação que ela vai dar ao art. 42 do Código de Processo do Consumidor. E, ao meu ver, (...) não vai depender, embora sejam diferentes as relações de Direito Público ou Privado, por exemplo, nos temos que decidir a tese: se vai necessitar má-fé para devolver ou não, e isso independe de saber se é do Direito Público ou do Privado; (...)

Com o fito de cumprirmos o objetivo dos Embargos de Divergência – resolver teses jurídicas confrontantes dentro do STJ –, estamos, com efeito, diante de teses da Primeira Seção opostas às da Segunda Seção sobre a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, sobressaindo, ao fim, a irrelevância das modalidades de relações jurídicas específicas tratadas em cada Seção, ante a constatação de que nos julgados a relação jurídica base não influencia nas conclusões divergentes sobre a necessidade de elemento volitivo para a repetição de indébito em dobro.

Em nenhum dos acórdãos confrontados é afastada a aplicação do art. 42 do CDC em virtude da natureza da relação jurídica, o que também reforça a similitude fático-jurídica entre os casos.

Por outro lado, como à frente se verá, a natureza da relação jurídica possui relevância para exame de questão subsequente (modulação temporal) à tese fundamental aqui examinada – efetiva existência de culpa ou dolo –, a depender, claro, do que prevalecer no presente julgamento.

De qualquer sorte, frise-se, o acórdão embargado, originário da Quarta Turma, trata de cobrança indevida relacionada ao serviço público de telefonia, o que caracteriza a total semelhança com as hipóteses tratadas pela Primeira Seção, também de concessões de serviços públicos.

Conhecendo dos Embargos, passo à análise do mérito do recurso.

4. Aplicação do direito à espécie em Embargos de Divergência

Para fins de Embargos de Divergência, estamos, sem dúvida, perante entendimentos discrepantes entre a Primeira e a Segunda Seções no que tange à aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, dispositivo que incide sobre todas as relações de consumo, privadas ou públicas, individuais ou coletivas.

Registro a compreensão firmada no STJ de que, em análise meritória de Embargos de Divergência, o órgão julgador não está adstrito às teses confrontadas, pois é possível adotar tese alternativa para aplicação do melhor direito à hipótese. Confira-se:

"Conhecidos os embargos de divergência, a decisão a ser adotada não se restringe às teses suscitadas nos arestos em confronto – recorrido e paradigma –, sendo possível aplicar-se uma terceira tese, pois cabe a Seção ou Corte aplicar o direito à espécie" (EREsp 513.608/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.11.2008). No mesmo sentido: "O exame dos embargos de divergência não se restringe às teses em confronto do acórdão embargado e do acórdão paradigma acerca da questão federal controvertida, podendo ser adotada uma terceira posição, caso prevalente" (EREsp 475.566/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 13.9.2004). Vejam-se precedentes: EREsp 130.605/DF, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, DJ 23.4.2001; e AgRg nos EREsp 901.919/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 21.9.2010.

5. Hermenêutica do sistema normativo de proteção do consumidor e o art. 42, parágrafo único, do CDC

Em harmonia com os ditames maiores do Estado Social de Direito, na tutela de sujeitos vulneráveis, assim como de bens, interesses e direitos supraindividuais, ao administrador e ao juiz incumbe exercitar o *diálogo das fontes*, de modo a – fieis ao espírito, *ratio* e princípios do microssistema ou da norma – realizarem material e não apenas formalmente os objetivos cogentes, mesmo que implícitos, abonados pelo texto legal.

Logo, interpretação e integração de preceitos legais e regulamentares de proteção do consumidor, codificados ou não, submetem-se a *postulado hermenêutico de ordem pública* segundo o qual, em caso de dúvida ou lacuna, o entendimento administrativo e o judicial devem expressar o posicionamento mais favorável à real superação da vulnerabilidade ou mais condutivo à tutela efetiva dos bens, interesses e direitos em questão.

Em síntese, não pode "ser aceita interpretação que contradiga as diretrizes do próprio Código, baseado nos princípios do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação de sua defesa em juízo" (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011). Na mesma linha da interpretação favorável ao consumidor: AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira

Turma, DJe 26/2/2016; REsp 1.726.225/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/9/2018; e REsp 1.106.827/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/10/2012. Confira-se também: "O mandamento constitucional de proteção do consumidor deve ser cumprido por todo o sistema jurídico, em diálogo de fontes, e não somente por intermédio do CDC" (REsp 1.009.591/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/8/2010).

A presente divergência deve ser solucionada à luz do *princípio da vulnerabilidade* e do *princípio da boa-fé objetiva*, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a *engano* e nega a devolução em dobro somente se for ele *justificável*. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a *justificabilidade* (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no *domínio da causalidade*, e não no *domínio da culpabilidade*, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva.

Cito outros precedentes (grifei):

> RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESPETÁCULOS CULTURAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE INGRESSOS NA INTERNET. COBRANÇA DE "TAXA DE CONVENIÊNCIA". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABERTAS E PRINCÍPIOS. BOA FÉ OBJETIVA. LESÃO ENORME. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. VENDA CASADA ("TYING ARRANGEMENT"). OFENSA À LIBERDADE DE CONTRATAR. TRANSFERÊNCIA DE RISCOS DO EMPREENDIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DAS VANTAGENS. DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.
>
> 1. Cuida-se de ação coletiva de consumo na qual se pleiteia, essencialmente: a) o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de "taxa de conveniência" pelo simples fato de a recorrida oferecer a venda de ingressos na internet; b) a condenação da recorrida em danos morais coletivos; e c) a condenação em danos materiais, correspondentes ao ressarcimento aos consumidores dos valores cobrados a título de taxa de conveniência nos últimos 5 (cinco) anos.

(...)

5. A essência do microssistema de defesa do consumidor se encontra no reconhecimento de sua *vulnerabilidade* em relação aos fornecedores de produtos e serviços, que detêm todo o controle do mercado, ou seja, sobre o que produzir, como produzir e para quem produzir, sem falar-se na fixação de suas margens de lucro.

(...)

23. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, parcialmente provido. (REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 15/3/2019).

DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DISTINÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO E INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA. ROTULAGEM. PROTEÇÃO DE CONSUMIDORES HIPERVULNERÁVEIS. CAMPO DE APLICAÇÃO DA LEI DO GLÚTEN (LEI 8.543/92 AB-ROGADA PELA LEI 10.674/2003) E EVENTUAL ANTINOMIA COM O ART. 31 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. JUSTO RECEIO DA IMPETRANTE DE OFENSA À SUA LIVRE INICIATIVA E À COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS POR DEIXAR DE ADVERTIR SOBRE OS RISCOS DO GLÚTEN AOS DOENTES CELÍACOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

(...) 3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de *ordem pública e interesse social*. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão *ex ante* e no atacado.

4. O ponto de partida do CDC é a afirmação do *Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor*, mecanismo que visa a garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer compactuar com exageros que, sem utilidade real, obstem o progresso tecnológico, a circulação dos bens de consumo e a própria lucratividade dos negócios.

(...)

22. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2009).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA A PASSE LIVRE NO TRANSPORTE

RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEI DE PROTEÇÃO DE SUJEITOS VULNERÁVEIS. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. EFEITOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. PRECEDENTES DO STJ. LEI 8.899/1994. LIMITAÇÃO DO DECRETO 3.691/2000. ANÁLISE DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO RECONHECIDA. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DO PEDIDO NO PROCESSO CIVIL COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 128, 264, 282, 293 E 294 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

(...)

2. Em caso de dúvida ou lacuna, a legislação de proteção de sujeitos vulneráveis deve ser interpretada ou integrada da forma que lhes seja mais favorável, vedado ao administrador e ao juiz acrescentar, acentuar ou inferir limitações ao exercício pleno dos direitos individuais e sociais previstos na Constituição e nas leis. Exatamente em decorrência da particular condição física, mental ou sensorial a exigir atenção elevada e prioritária para que se viabilize por completo sua inalienável dignidade humana, as pessoas com deficiência precisam de mais direitos – e também de direitos mais eficazes –, predicado não só inseparável do Estado Social de Direito, constitucionalizado em 1988, como também indicador do grau de civilização dos brasileiros.

(...)

8. Recursos Especiais não providos.

(REsp 1568331/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2018).

6. Reposicionamento pessoal sobre a matéria

A posição que passo a perfilhar aqui não é exatamente aquela por mim expressada em precedentes de minha relatoria.

Nesse sentido, ao apresentar a tese a seguir exposta, reposiciono-me a respeito dos critérios do parágrafo único do art. 42 do CDC, de modo a reconhecer que **a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a *boa-fé objetiva do fornecedor* na cobrança realizada**.

Adoto, pois, a posição que se formou na Corte Especial, lastreada no princípio da boa-fé objetiva e consequente descasamento de elemento volitivo, consoante Voto-Vista do Ministro **Luis Felipe Salomão** e manifestações apresentadas pelos eminentes Pares, na esteira de intensos e ricos debates nas várias sessões em que o tema foi analisado.

Realço, nesse ponto, trecho relevante do Voto do Ministro **Og Fernandes**: "A

restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Na hipótese dos autos, necessário, **para fins de parcial modulação temporal de efeitos**, fazer distinção entre contratos de serviços públicos e contratos estritamente privados, sem intervenção do Estado ou de concessionárias.

7. Aplicação do art. 42 do CDC aos contratos que envolvam o Estado ou suas concessionárias de serviços públicos

Na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve prevalecer o **princípio da boa-fé objetiva**, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.

A esse respeito, o entendimento prevalente nas Turmas da Primeira Seção do STJ é o de rechaçar a exigência de dolo, posição sem dúvida inspirada na preeminência e inafastabilidade do princípio da vulnerabilidade do consumidor e do princípio da boa-fé objetiva. A propósito: REsp 1.085.947/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 12/11/2008; AgRg no REsp 1.363.177/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/5/2013; REsp 1.300.032/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.307.666/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/3/2013; AgRg no REsp 1.376.770/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.9.2016; AgRg no REsp 1.516.814/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.8.2015; AgRg no REsp 1.158.038/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/5/2010; AgInt no REsp 1.605.448/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/12/2017; AgRg no AgRg no AREsp 550.660/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/12/2015; AgRg no AREsp 723.170/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; AgRg no Ag 1.400.388/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2014.

Na Segunda Seção há também precedente que rejeita o requisito do dolo para

repetição do indébito em dobro: "Somente na presença de má-fé ou culpa o pagamento em dobro é devido" (AgRg no AREsp 162.232/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.8.2013).

Agrega-se ao raciocínio construído na Primeira Seção a regra geral de que a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é *objetiva* em relação aos danos causados a terceiros (art. 37, § 6º, da CF/1988).

Cito precedentes do STJ sobre o tema:

> ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTAMINAÇÃO DE HEMOFÍLICOS COM O VÍRUS HIV (AIDS) E HCV (HEPATITE C). OMISSÃO ESTATAL NO CONTROLE DO SANGUE. DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO ESTADO. DECISÃO EXTRA PETITA. LEI 4.701/65.
>
> (...)
>
> 6. Responsabilidade objetiva do Estado, com base na teoria do risco administrativo, por contaminação com o vírus HIV e HCV (hepatite C), em decorrência de transfusão de sangue. Dano e nexo causal reconhecidos pelo Tribunal de Origem. Não se observa excludente de culpabilidade no caso em análise. Reconhece-se a conduta danosa da Administração Pública ao não tomar as medidas cabíveis para o controle da pandemia. No início da década de 80, já era notícia no mundo científico de que a AIDS poderia ser transmitida pelas transfusões de sangue. O desconhecimento acerca do vírus transmissor (HIV) não exonera o Poder Público de adotar medidas para mitigar os efeitos de uma pandemia ou epidemia. Princípio da Precaução no âmbito do Direito Administrativo.
>
> (...)
>
> Recursos especiais conhecidos em parte e parcialmente providos. (REsp 1299900/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/3/2015, DJe 13/03/2015).

> PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE INTERNO DA FUNDAÇÃO CASA DURANTE REBELIÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTES STJ. TEMA JULGADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
>
> 1. É vedado, em sede de agravo interno, ampliar-se o objeto da impugnação apresentada em contraminuta de agravo em recurso especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.
>
> 2. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido que o Estado possui *responsabilidade objetiva* no casos de morte de presos sob a sua

custódia prisional. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1581961/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/9/2016, DJe 14/9/2016).

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 (ART. 1.022 DO CPC/2015). LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 E 460 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

(...)

IV - Antes de adentar ao mérito propriamente dito, mister se faz a apreciação da preliminar de ilegitimidade de parte passiva, arguida pela empresa Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. e pelo Estado do Mato Grosso. As alegações deduzidas pelos recorrentes em suas razões não merecem prosperar. *Isso, porque a primeira apelante, na qualidade de prestadora de serviço público de energia elétrica, sujeita-se às normas do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, trata da responsabilidade objetiva da administração***.** Quanto ao Estado de Mato Grosso, no mesmo sentido, deve responder pelos danos causados ao apelado, pois se descurou do dever de fiscalizar os serviços que lhe competia fazer. Assim, o Estado do Mato Grosso é pessoa legítima para figurar no polo passivo da presente ação.

(...)

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1711214/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 18/11/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é *objetiva*, pois deve o Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1238182/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/9/2018).

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATROPELAMENTO FATAL. TRAVESSIA NA FAIXA DE PEDESTRE. RODOVIA SOB CONCESSÃO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO.

CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO. ART. 37, § 6°, CF. VIA EM MANUTENÇÃO. FALTA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO PRECÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS.

(...)

2. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem *objetivamente* pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes.

(...)

4. "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 7/4/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TABELIÃO E SUBSIDIÁRIA DO ESTADO.

1. O acórdão recorrido encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual nos casos de danos resultantes de atividade estatal delegada pelo Poder Público, há *responsabilidade objetiva* do notário, nos termos do art. 22 da Lei 8.935/1994, e apenas subsidiária do ente estatal. Precedentes: AgRg no AREsp 474.524/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/06/2014; AgRg no AgRg no AREsp 273.876/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/05/2013; REsp 1.163.652/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2010.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1377074/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/2/2016).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA. INDICAÇÃO DE CONTA NÃO PERTENCENTE À PESSOA BENEFICIÁRIA. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. É *objetiva* a responsabilidade civil do Estado pelos danos

causados por seus agentes no exercício da função pública, cabendo ao prejudicado, unicamente, comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o dano suportado, sem a necessidade de demonstrar a existência de culpa.

(...)

6. Recurso especial do particular parcialmente provido.

(REsp 1038259/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/2/2018).

O STF sedimentou, sob o rito da Repercussão Geral, a posição de que "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal." (RE 591.874, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 26.8.2009, Repercussão Geral – Mérito, DJe 18.12.2009).

Na mesma linha:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS USUÁRIOS OU NÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.

(...)

3. No tocante ao art. 37, § 6º, da Carta Magna, o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria encontra-se firmado no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente por suas ações ou omissões em face de reparação de danos materiais suportados por terceiros.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).

(ARE 1043232 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 12-09-2017 PUBLIC 13-09-2017).

E M E N T A: ATO DE REGISTRO DE COMÉRCIO – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – JUCERJA (AUTARQUIA ESTADUAL) – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, § 6º) – CONFIGURAÇÃO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – DOUTRINA E PRECEDENTES EM TEMA

> DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DE QUE SE CUIDA DE RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE REAPRECIE A CAUSA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
>
> (ARE 1046474 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017).
>
> EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
>
> 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os elementos configuradores da responsabilidade objetiva do Estado são: (i) existência de dano; (ii) prova da conduta da Administração; (iii) presença do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano ocorrido; e (iv) ausência de causa excludente da responsabilidade.
>
> (...)
>
> 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público possui responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários e não usuários do serviço público. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa.
>
> (ARE 886570 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017)

Ora, se a regra da responsabilidade civil objetiva impera, universalmente, em prestações de serviço público, como admitir que, nas relações de consumo – na presença de sujeito (consumidor) caracterizado *ope legis* como vulnerável (CDC, art. 4º, I) –, o paradigma jurídico seja o da responsabilidade subjetiva (com dolo ou culpa)? Seria contrassenso atribuir tal privilégio ao fornecedor, mormente por ser fato notório que dezenas de milhões dos destinatários finais dos serviços públicos, afligidos por cobranças indevidas, personificam não só sujeitos vulneráveis, como também sujeitos indefesos e hipossuficientes econômica e juridicamente, ou seja, carentes em sentido lato, destituídos de meios financeiros, de informação e de acesso à Justiça.

Compreensão distinta, centrada na necessidade de prova de elemento volitivo,

na realidade inviabiliza a devolução em dobro, p. ex., de pacotes de serviços telefônicos jamais solicitados pelo consumidor, bastando ao fornecedor invocar uma justificativa qualquer para seu engano. Nas condições do mercado de consumo massificado, impor ao consumidor prova de dolo ou culpa corresponde a castigá-lo com ônus incompatível com os princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, legitimando, ao contrário dos cânones do microssistema, verdadeira *prova diabólica*, o que contraria frontalmente a filosofia e *ratio* eticossocial do CDC.

Assim, a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como *elemento de causalidade,* e não como *elemento de culpabilidade*.

8. Aplicação do art. 42 do CDC aos contratos que não envolvam prestação de serviços públicos

Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários, de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção.

Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, que ainda está pendente de julgamento. Na sessão da Corte Especial de exame dos EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que **a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a *boa-fé objetiva do fornecedor* na cobrança realizada**. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de *variável da equação de causalidade,* e não de *elemento de culpabilidad*e, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que deu causa ao indébito.

9. Síntese da proposta de tese resolutiva da divergência jurisprudencial

A proposta aqui trazida – que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos **Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO** – consiste em **reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta** (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a **boa-fé objetiva do fornecedor** para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

Registram-se trechos dos Votos proferidos que contribuíram diretamente ou serviram de inspiração para a posição aqui adotada (grifos acrescentados):

MINISTRA NANCY ANDRIGHI: "O requisito da comprovação da má-fé não consta do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem em qualquer outro dispositivo da legislação consumerista. A parte final da mencionada regra – 'salvo hipótese de engano justificável' – *não pode ser compreendida como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor*".

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: "Os requisitos legais para a repetição em dobro na relação de consumo são a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável do fornecedor. *A exigência de indícios mínimos de má-fé objetiva do fornecedor é requisito não previsto na lei e, a toda evidência, prejudica a parte frágil da relação.*"

MINISTRO OG FERNANDES: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) *independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva*."

MINISTRO RAUL ARAÚJO: "Para a aplicação da sanção civil prevista no

art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de *conduta contrária à boa-fé objetiva* para justificar a reprimenda civil de imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente."

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: "O código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar *a concepção objetiva* do abuso do direito, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, *prescindindo da verificação da intenção do agente – dolo ou culpa* – para caracterização de uma conduta como abusiva (...) Não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, *objetivamente*, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável."

Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia: **a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.**

10. Parcial modulação temporal de efeitos da decisão

Preconiza o art. 927, § 3º, do CPC/2015:

> Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
> (...)
> § 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

A novel legislação processual prevê, portanto, a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais

superiores.

A Corte Especial já se manifestou sobre a possibilidade de modulação de efeitos de suas decisões no REsp 1.696.396/MT (Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018) e traçou parâmetros relevantes a considerar:

> Para proporcionar a necessária segurança jurídica, não há objeção ou dificuldade em se criar, para a situação em exame, *um regime de transição que module os efeitos da decisão desta Corte, caso seja adotada a tese jurídica da taxatividade mitigada*.
>
> Isso porque o art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, introduzido pela Lei nº 13.655/2018, expressamente prevê que *"a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais"*.
>
> Adotado o regime de transição, a modulação será feita com a aplicação da tese somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que a fixar.

Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

Parece prudente e justo, portanto, que se deva **modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação deste acórdão**.

11. Caso concreto

No caso dos autos, o *acórdão recorrido* fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação

de serviço público de telefonia.

Assim, os Embargos de Divergência merecem ser providos para impor a devolução em dobro do indébito.

12. Conclusão

Com essas considerações, peço vênias para divergir do bem fundamentado voto da e. Relatora, Ministro Maria Thereza de Assis Moura, rendendo homenagens aos judiciosos votos dos e. Ministros que me antecederam, para **conhecer dos Embargos de Divergência e, no mérito, dar-lhes provimento**, de forma a:

a) estabelecer que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo;

b) modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço público pagos após a data da publicação do presente acórdão; e

c) determinar a devolução em dobro do indébito no caso concreto.

É como **voto**.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2013/0355826-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EREsp 1.413.542 / RS**

Números Origem: 00024664120118210124 00382183920138217000 11100012910 12111794201382170000 12411100012910 24664120118210124 382183920138217000 70052756772 70053135935 70053964904

PAUTA: 05/12/2018 JULGADO: 20/02/2019

Relatora
Exma. Sra. Ministra **MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro : **BENEDITO GONÇALVES**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE	:	PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539 ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO	:	BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS	:	TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227 CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494 ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por Dano Moral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Herman Benjamin conhecendo dos embargos de divergência e dando-lhes provimento, pediu vista o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Aguardam os Srs. Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Felix Fischer, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Humberto Martins.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**
EMBARGANTE	:	PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539 ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO	:	BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS	:	TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227 CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494 ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:

1. Cuida-se de embargos de divergência interpostos por Pedro Lugoch em face de acórdão proferido pela Quarta Turma, assim ementado:

> AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
> 1. A repetição de indébito em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor não prescinde da prova de má-fé do credor. Incidência da Súmula 83/STJ.
> 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

Em suas razões, o embargante aponta divergência entre o acórdão supracitado e precedentes das Turmas de Direito Público, segundo os quais basta a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor na cobrança indevida de serviços públicos concedidos (**AgRg no AREsp 262.212/RS**, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19.02.2013, DJe 07.03.2013; e **AgRg no AREsp 371.431/MS**, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17.10.2013, DJe 22.10.2013).

De acordo com o autor da ação de repetição de indébito, a prova da má-fé do fornecedor não é requisito para a incidência da sanção civil de pagamento em dobro, prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que exige tão somente a demonstração de engano injustificável.

Na sessão de julgamento da Corte Especial de 2.5.2018, a eminente relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, conheceu dos embargos de divergência, dando-lhes provimento, a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados pela embargada, por considerar

desnecessária a comprovação da má-fé do credor, mas tão somente a culpa.

Eis os fundamentos perfilhados no voto da relatora:

> Vale dizer, enquanto as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte entendem que basta a culpa para a devolução em dobro, as Turmas de Direito Privado acentuam que mister a comprovação da má-fé do credor na cobrança indevida.
> Tal distinção já foi, inclusive, abordada por Leonardo de Medeiros Garcia, na obra Direito do Consumidor, Código Comentado e Jurisprudência, 8ª edição, 2012, Editora Impetus, p. 319/321, *verbis*:
> (...)
> Nesse passo, cumpre definir quais são os critérios para a devolução em dobro do indébito.
> Da letra da lei extrai-se que a repetição em dobro depende da cobrança indevida, do pagamento em excesso, bem como da inexistência de engano justificável do fornecedor/credor.
> E o que seria o engano justificável? Com a devida vênia, acompanho a lição do Ministro Herman Benjamin, quando do exame do REsp 1079064/SP, Segunda Turma, julgado em 02/04/2009, DJe de 20/04/2009, no sentido de que "o engano é justificável exatamente quando não decorre de dolo ou de culpa" (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, 9ª ed., Rio de janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 408).
> Ou seja, ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, não é necessária a comprovação da má-fé do credor, basta a culpa.
> A meu sentir, a conclusão de que a expressão "salvo hipótese de engano justificável" significa "comprovação da má-fé do credor" diminui o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo.
> Nesse contexto, penso que deve prevalecer a orientação das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte quanto ao tema.
> No caso concreto, asseverou o Tribunal local que a repetição do indébito deveria se dar na forma simples porque não demonstrada a má-fé da empresa de telefonia na cobrança dos valores, razão pela qual deve ser reformado o acórdão.

Na ocasião, o eminente Ministro Herman Benjamin pediu vista e, em 20.2.2019, apresentou voto acompanhando parcialmente a relatora, a fim de: (i) **estabelecer que a devolução em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) ocorre quando o comportamento do fornecedor for doloso ou culposo**; (ii) **modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos que não decorram da prestação de serviço público pagos após a data da conclusão do presente julgamento**; e (iii) no caso específico, impor a devolução em dobro do indébito.

Pedi vista dos presentes autos, bem como dos referentes aos **Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 600.663/RS** (também da relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura), **664.888/RS** (Rel. Ministro Herman Benjamin), **622.897/RS** (Rel. Ministro Raul Araújo) e **676.608/RS** (Rel. Ministro Og Fernandes), que

tratam do mesmo tema.

É o relatório complementar.

2. No caso em julgamento, a petição inicial relata cobranças por serviços telefônicos não solicitados, o que reflete má prestação por parte do fornecedor Brasil Telecom, por isso pleiteou a declaração da inexigibilidade das cobranças e devolução em dobro dos valores pagos, além de indenização por dano moral. O magistrado de piso julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a irregularidade das cobranças e determinando a repetição em dobro, o que foi mantido pelo Tribunal gaúcho. A Quarta Turma, por sua vez, manteve decisão monocrática da lavra da eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, que deu parcial provimento ao recurso especial da Brasil Telecom para afastar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Nesse passo, como de sabença, o código consumerista é um microssistema jurídico interdisciplinar, que estabelece normas de ordem pública e de interesse social, que, de um lado, reconhecem direitos subjetivos à parte mais fraca da relação de consumo – o consumidor – e, de outro, estipulam deveres jurídicos – regras gerais ou padrões de conduta – a serem observados pelo fornecedor, além das respectivas consequências jurídicas em caso de descumprimento, tudo isso com o escopo de reequilibrar a desigualdade fática entre os sujeitos.

No dizer de Bruno Miragem, o direito do consumidor, *"ao mesmo tempo em que tem por diretriz fundamental a proteção e promoção da igualdade entre as partes (consumidores e fornecedores), também tem como efeito o aperfeiçoamento do mercado de consumo, por intermédio da regulação do comportamento de seus agentes"* (*Curso de direito do consumidor* [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Nesse mister, o CDC estabelece uma proibição geral ao abuso do direito do fornecedor – detentor de posição privilegiada –, enumerando direitos básicos (e indisponíveis) do consumidor, entre os quais se insere a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais e contra práticas abusivas adotadas no fornecimento de produtos ou serviços (artigo 6º, inciso IV).

Sob tal ótica, exsurge o artigo 42 do CDC – cuja interpretação é objeto dos presentes embargos de divergência –, que descreve prática abusiva consistente na "cobrança irregular de dívidas de consumo", tutelando, expressamente, a integridade moral e a dignidade do consumidor. Confira-se:

> **Art. 42.** Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
> **Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que**

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Malgrado se reconheça que a cobrança de débitos pelo fornecedor constitui exercício regular de direito, o dispositivo legal encarta normas jurídicas que vedam, expressamente, quaisquer abusos perpetrados com o escopo de obter a quitação de uma dívida, bem como aquele consubstanciado na exigência de valor indevido.

A norma de conduta inserta no *caput* do artigo proíbe que a cobrança de débitos de consumo seja realizada mediante ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, emprego de afirmações falsas, incorretas ou enganosas, bem como que o consumidor seja exposto a ridículo ou haja interferência em seu trabalho, descanso ou lazer.

O **parágrafo único**, por sua vez, traz indiscutível norma sancionatória da conduta consubstanciada na **cobrança de dívida inexistente ou em valor maior que o devido**, cominando ao fornecedor a penalidade civil de **repetição em dobro do excesso cobrado**, *"salvo hipótese de **engano justificável**"*.

Em sede doutrinária e jurisprudencial, é incontroverso o entendimento de que os **elementos objetivos** do "tipo legal" (ensejador da incidência da sanção civil), são: **(i)** a cobrança extrajudicial indevida de dívida decorrente de contrato de consumo; e **(ii)** o efetivo pagamento do indébito pelo consumidor.

De outro lado, há o **elemento subjetivo** da conduta, em relação ao qual as Turmas de Direito Privado e as de Direito Público, ***aparentemente***, controvertem: **(i)** a **má-fé**, consoante assente na Segunda Seção; ou **(ii)** a **culpa** e o **dolo**, nos termos da jurisprudência da Primeira Seção.

3. Deveras, o parágrafo único do artigo 42 do CDC tem por objetivo coibir o exercício abusivo e opressivo da posição dominante do fornecedor, cominando a penalidade de devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada da parte vulnerável da relação de consumo, que, muitas vezes, demora a ter ciência do excesso exigido ou, ainda quando ciente, vê-se obrigada a efetuar o pagamento a fim de garantir a continuidade do serviço prestado (notadamente quando se trata de serviço público essencial) ou a não inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes.

De fato, o código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar a **concepção objetiva do abuso do direito**, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, prescindindo da verificação da intenção do agente (dolo ou culpa) para caracterização de uma conduta como abusiva.

Nessa perspectiva, o princípio da boa-fé objetiva figura como parâmetro

principal de valoração do comportamento das partes, sobretudo do fornecedor, que, sendo titular de posição privilegiada, deve adotar as cautelas necessárias para evitar a quebra de confiança e a frustração das legítimas expectativas da parte vulnerável da relação de consumo.

Na lição de Cláudia Lima Marques, a boa-fé objetiva *"significa atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes"* (*Contratos no Código de Defesa do Consumidor*. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

Em sua função de controle, a boa-fé objetiva serve de limite ao exercício dos direitos subjetivos, *"seja reduzindo a liberdade dos parceiros contratuais aos definir algumas condutas como abusivas, seja controlando a transferência dos riscos profissionais e liberando o devedor em face da não razoabilidade de outra conduta"* (MARQUES, Cláudia Lima. *Op. cit*. p. 215).

Nesse sentido, a boa-fé traduz o padrão ético de confiança e lealdade que deve ser observado em qualquer relação jurídica, coibindo os excessos no exercício dos direitos subjetivos e, consequentemente, possibilitando a convivência social harmônica.

De outro lado, também se deve destacar a função criadora – também chamada de integrativa – da boa-fé objetiva, concebida como fonte autônoma de deveres anexos, instrumentais, laterais ou acessórios, tais como os deveres de informar, de cuidado, de lealdade e de cooperação.

Diante deste cenário, segundo penso, é que se deve dimensionar o conteúdo da jurisprudência da Segunda Seção, que, ao interpretar a norma inserta no parágrafo único do artigo 42 do CDC, considera necessária a constatação da má-fé do fornecedor para a aplicação da sanção civil de repetição em dobro.

Salta aos olhos, assim, que a expressão "má-fé", constante dos precedentes da Segunda Seção, não foi empregada como sinônimo de "dolo" – que, sabidamente, não é exigido para configuração do exercício abusivo do direito (à luz da concepção objetiva adotada pelo CDC) –, mas, sim, como conduta contrária à boa-fé objetiva, que abrange os deveres anexos de cuidado, zelo e proteção nas relações jurídicas.

De acordo com as Turmas de Direito Privado, portanto, o "engano justificável", na cobrança de dívida de consumo, não afasta a boa-fé objetiva, mas, *a contrario sensu*, o "engano injustificável" caracteriza a má-fé do fornecedor, que "erra" quando não poderia

"errar", tendo em vista as cautelas que lhe são exigidas por força de sua posição jurídica privilegiada.

Assim, a falta de cuidado (diligência, zelo) imposto ao fornecedor, quando da cobrança da dívida, é que qualifica o engano como injustificável e, consequentemente, caracteriza a conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, a má-fé.

Nesse sentido, não há que perquirir a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável.

Deve-se analisar, no caso concreto, se a cobrança indevida decorreu ou não de conduta deliberada – inobservância do dever anexo de lealdade – ou mesmo leviana do fornecedor, ao descumprir seu dever anexo de proteção (cuidado) para com a integridade pessoal e patrimonial do consumidor.

Sob tal ótica, **há inúmeros precedentes das Turmas de Direito Privado que pugnam pela inexistência de má-fé do fornecedor** – ou seja, inexistência de conduta contrária à boa-fé objetiva e, portanto, configurada hipótese de engano justificável –, **quando**: **(i)** o pagamento tiver sido efetuado em decorrência de cláusula contratual posteriormente declarada nula; ou **(ii)** houver controvérsia judicial em relação ao objeto da cobrança indevida. Confira-se:

> Ação de repetição do indébito. Art. 965 do Código Civil de 1916. Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Súmula nº 07 da Corte.
> 1. Já decidiu a Corte que àquele que recebeu o que não era devido, cabe fazer a restituição, sob pena de enriquecimento sem causa, pouco relevando a prova do erro no pagamento, em caso de contrato de abertura de crédito.
> **2. No caso, não cabe a restituição em dobro, na guarida do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ausentes os seus pressupostos, considerando que o tema dos juros e encargos cobrados pelas instituições financeiras tem suscitado controvérsia judicial, até hoje submetida a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas operações bancárias ao exame do Supremo Tribunal Federal.**
> (...)
> 4. Recurso especial conhecido e provido, em parte. (**REsp 505.734/MA**, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 20.05.2003, **DJ 23.06.2003**) (grifei)
> ---
> Contrato bancário. Natureza jurídica do contrato. Seguro. Prequestionamento. Código de Defesa do Consumidor. Juros. Capitalização. Taxa Referencial (TR). Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Súmula nº 297 da Corte.
> (...)
> 6. **O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,**

relativo à repetição em dobro, não se aplica quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais.
7. Recurso dos autores não conhecido e recurso especial da instituição financeira parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (**REsp 549.665/RS**, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 05.10.2004, **DJ 01.02.2005**) (grifei)

CIVIL. CLÁUSULA NULA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. **O pagamento resultante de cláusula contratual mais tarde declarada nula em sede judicial deve ser devolvido de modo simples, e não em dobro; age no exercício regular de direito quem recebe a prestação prevista em contrato**.
Embargos de divergência conhecidos e providos. (**EREsp 328.338/MG**, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, julgado em 26.10.2005, **DJ 01.02.2006**) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 83. (...) CDC, ART. 42.
- **Não incide a sanção do Art. 42, parágrafo único, do CDC, quando o encargo considerado indevido é objeto de controvérsia jurisprudencial**. (**AgRg no Ag 764.333/RS**, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 19.09.2006, **DJ 16.10.2006**) (grifei)

AÇÃO REVISIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AMORTIZAÇÃO. REAJUSTE PRÉVIO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DÉBITO OBJETO DE DEMANDA. INVIABILIDADE. TABELA *PRICE*. CAPITALIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANATOCISMO. VEDAÇÃO. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. TR. UTILIZAÇÃO. LEGALIDADE.
(...)
lll - **É incabível a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando o débito tem origem em encargos cuja validade é objeto de discussão judicial.**
(...) (**REsp 756.973/RS**, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 27.03.2007, **DJ 16.04.2007**)

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE.
I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.
II - No caso, **a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a**

conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé.
Recurso Especial provido. (**REsp 871.825/RJ**, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 12.08.2010, **DJe 23.08.2010**) (grifei)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA (REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO) - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284/STF - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO E, POR ISSO, NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - REPETIÇÃO EM DOBRO - PRESSUPOSIÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ - NECESSIDADE - COBRANÇA DE ENCARGOS REPUTADOS INDEVIDOS - AFASTAMENTO DA PENALIDADE - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
I - **A declaração de ilegalidade da cobrança de encargos insertos nas cláusulas contratuais, ainda que importe a devolução dos respectivos valores, não enseja a repetição em dobro do indébito, diante da inequívoca ausência de má-fé. Este entendimento estriba-se no argumento de que a consecução dos termos contratados, a considerar a obrigatoriedade que o contrato encerra, vinculando as partes contratantes, não revela má-fé do fornecedor, ainda, que, posteriormente, reste reconhecida a ilicitude de determinada cláusula contratual;**
II - *In casu*, ao contrário do que restou decidido pelo Tribunal de origem, não se constata sequer a ocorrência de distanciamento dos termos contratados pela empresa-construtora, ora recorrente, por aplicar, como índice de correção monetária, a TR (Taxa Referencial), em substituição à UPDF's (Unidade de Financiamento Padrão Diária), extinta em 1.7.1994.
III - Inexistindo cláusula contratual que preceituasse o índice substitutivo (como aduzido pelo Tribunal de origem, ressalte-se) e sendo este devido, já que não se afigura escorreito, tampouco razoável, que a prestação remanescesse estática, a adoção da TR, ainda que se revelasse, posteriormente, descabida, inocorrente erro grosseiro e, muito menos, má-fé da contratante a supedanear a repetição dobrada;
IV - Recurso Especial parcialmente provido. (**REsp 1.060.001/DF**, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011, **DJe 24.02.2011**) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE IDADE. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE CONTRATO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS, E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
5. **A iniciativa da empresa recorrida de reajustar as prestações do plano de saúde, com base na mudança da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual e presumidamente aceita pelas partes. Desse modo, não há razão para concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé, de forma a possibilitar a repetição em dobro de valores.** Precedentes.

> 6. Agravo interno não provido. (**AgInt no AREsp 915.579/SP**, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22.08.2017, **DJe 29.08.2017**)

Por outro turno, há julgados da Segunda Seção e das respectivas Turmas no sentido do cabimento da repetição em dobro em casos nos quais considerado **injustificável o engano** perpetrado pelo fornecedor por ocasião da cobrança indevida de dívida:

> Ação civil pública. Direitos individuais homogêneos. **Cobrança de taxas indevidas. Candidatos a inquilinos. Administradoras de imóveis.** Legitimidade ativa do PROCON - Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, por meio da Procuradoria Geral do Estado para ajuizar ação coletiva para proteção de direitos individuais homogêneos. Prescrição. Multa do art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Repetição em dobro. Multa do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Súmula n° 07 da Corte.
> Precedentes.
> (...)
> 4. **A repetição do indébito pelo valor em dobro não se impõe quando presente engano justificável, o que não é o caso quando o Acórdão recorrido identifica a existência de fraude à lei.**
> 5. O exame da documentação existente, que serviu de fundamento para a configuração da taxa cobrada como de intermediação, vedada na Lei especial de regência, não pode ser reexaminada, a teor da Súmula n° 07 da Corte.
> (...)
> 7. Recursos especiais conhecidos e providos, em parte. (**REsp 200.827/SP**, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 26.08.2002, **DJ 09.12.2002**)
> ---
> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. APONTAMENTO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DOBRADA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 42 DO CDC. ENGANO NÃO JUSTIFICADO.
> (...)
> 3. Repetição dobrada do valor. Artigo 42 do CDC. **Não demonstrado pelo recorrente ser justificável o engano relativo ao repasse ao cartão Visa de créditos do pagamento de faturas do cartão Mastercard, por conta de numeração equivocada.** Correção do fundamento do aresto recorrido. Condenação mantida.
> 4. AGRAVO DESPROVIDO. (**AgRg no REsp 1.200.417/MT**, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14.08.2012, **DJe 20.08.2012**)
> ---
> EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - CIVIL E CONSUMIDOR - AÇÃO DE COBRANÇA - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO - PRIVATIZAÇÃO DA COPESUL - AQUISIÇÃO DE AÇÕES - MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO - VALORES COBRADOS A MAIOR - RESSARCIMENTO EM DOBRO - CABIMENTO - MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO

CDC.
1. Incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado acerca da viabilidade da repetição em dobro de valores nos casos em que comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida.
A cobrança indevida caracterizou-se pela conduta da casa bancária de exigir dos mutuários, no bojo de contrato de mútuo, quantia superior à efetivamente utilizada para a aquisição das ações, diferença que passou a existir em decorrência de deságio sofrido pelas moedas da privatização.
Não integra o conceito de engano justificável a conduta da embargante que, na condição de instituição financeira mandatária, constituída por consumidor para a realização de negócio jurídico de aquisição de ações, descumpre cláusula expressa da avença e, mesmo após reiteradas solicitações dos mandantes para a prestação de contas, atinente à comprovação do valor pago pelas moedas da privatização, recusa-se ao cumprimento da obrigação. Má-fé caracterizada, devendo haver a devolução em dobro das quantias indevidamente exigidas.
2. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos. (**EREsp 867.132/RS**, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 28.11.2012, **DJe 12.03.2013**)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. **A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido da obrigatoriedade da restituição em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor, salvo no caso de engano justificável, circunstância afastada pelo acórdão recorrido.**
(...)
3. Agravo regimental a que se nega seguimento. (**AgRg no REsp 1.427.535/RS**, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03.02.2015, **DJe 09.02.2015**)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO ALEGADA OMISSÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. **Não se tratando de engano justificável, circunstância afastada pelo acórdão recorrido, cabe a restituição em dobro do valor debitado indevidamente da conta do autor.**
3. Agravo regimental não provido. (**AgRg no AREsp 619.334/ES**, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12.05.2015, **DJe 18.05.2015**)

Antes de encerrar este tópico, mister um registro.

Com efeito, esta Corte Especial, recentemente, quando da conclusão do julgamento do **EAREsp 738.991/RS**, da relatoria do eminente Ministro Og Fernandes,

assinalou na ementa (publicada em 11.6.2019) uma afirmação que, salvo melhor juízo, não se coaduna com os respectivos autos nem retrata a exegese firmada pela maioria dos integrantes da Corte Especial.

É que, no item 2 da referida ementa, aplicou-se a Súmula 168/STJ a fim de se conhecer apenas parcialmente dos embargos, sob o fundamento de **estar pacificado o cabimento da repetição em dobro nos casos em que demonstrada a má-fé do credor**.

Contudo, tal assertiva, com a máxima vênia, configura equívoco, pois a tese sobre o artigo 42 do CDC não foi objeto do recurso especial nem do agravo nem dos embargos de divergência, não tendo sido sequer tratada pelos demais Ministros, ainda que fosse para também aplicar a Súmula 168/STJ.

O eminente Ministro Herman Benjamin, por ocasião da apresentação de seu voto-vista, bem explicitou que o referido recurso (**EAREsp 738.991/RS**) limitou-se a impugnar a questão do prazo prescricional. Confira-se:

> Observo, apenas, que os Embargos de Divergência foram interpostos com a finalidade de discutir, exclusivamente, a exegese que deve prevalecer em relação ao prazo prescricional a incidir na hipótese dos autos (ou seja, o estabelecido no art. 205 ou no art. 206, § 3º, IV, do CC). **Com a vênia do e. Ministro Relator, a leitura das razões recursais evidencia que não houve nenhuma manifestação do embargante relativa a suposto dissídio na interpretação do art. 42 do CDC, razão pela qual, nesse ponto, não se trata de aplicar a Súmula 168/STJ – o tema, reitero, simplesmente não faz parte do objeto recursal.**

Dessa forma, apenas para registro, assinalo que o julgado em referência não tem força para, de qualquer modo, vincular o exame da controvérsia atinente à interpretação da norma inserta no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, objeto dos presentes embargos de divergência.

4. **Assim posta a questão, penso que a divergência entre a Primeira e a Segunda Seções é apenas aparente, mas que, todavia, vem gerando inúmeros problemas interpretativos e de aplicação das teses jurídicas.**

4.1. **De fato, embora se utilizem de expressões semânticas diferentes, ambos os órgãos julgadores ostentam o mesmo entendimento de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, revela-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, seja por força de inobservância do dever anexo de lealdade – ato deliberado, com intuito fraudulento e malicioso, de prejudicar o consumidor –, ou do dever anexo de proteção/cuidado, ensejando ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do**

vulnerável.

4.2. A clareza sobre o real alcance da expressão "má-fé" – para fins de incidência da sanção civil de repetição em dobro –, tal como exposto no raciocínio ora desenvolvido, poderá modificar, para melhor, a conduta indiligente de alguns fornecedores, que passarão a agir com maior cuidado/zelo/atenção quando os consumidores apontarem irregularidades nas cobranças de supostas dívidas, o que se coaduna com o princípio da harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo, previsto no inciso III do artigo 4º do CDC, que, além de determinar a observância à boa-fé objetiva, proíbe o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. Leia-se:

> Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes **princípios**:
> (...)
> **III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;**
> (...) (grifei)

4.3. Nessa linha de entendimento, uma vez apontada a cobrança indevida pelo consumidor, caberá ao fornecedor, na fase instrutória do processo, produzir prova apta a demonstrar que não atuou em contrariedade à boa-fé objetiva, isto é, que não agiu de forma desleal ou descuidada, pois o engano cometido era, sim, justificável, afastando-se, assim, a incidência da sanção civil de devolução em dobro.

4.4. Assim, em resumo, **a fim de afastar o aparente conflito entre as Turmas de Direito Privado e de Direito Público e, consequentemente, manter estável e coerente a jurisprudência desta Corte, prestigiando-se o postulado da segurança jurídica**, nos termos do artigo 926 do CPC de 2015, **creio seja fundamental estabelecer as seguintes premissas sobre o tema em julgamento**:

(i) **a sanção civil de devolução em dobro, encartada no parágrafo único do artigo 42 do CDC, revela-se possível quando a cobrança indevida consubstanciar má-fé, compreendida esta como conduta contrária à boa-fé objetiva**, seja por força de inobservância do dever anexo de lealdade – ato deliberado, com intuito fraudulento e malicioso, de prejudicar o consumidor –, ou do dever anexo de proteção – ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável;

(ii) nessa perspectiva, **caberá ao fornecedor, na contestação ou na fase instrutória do processo, demonstrar que não atuou em contrariedade à boa-fé objetiva**, isto é, que não agiu de forma desleal ou descuidada, pois o engano cometido era, sim, justificável; e

(iii) **se houver divergência jurisprudencial em relação ao objeto da cobrança indevida** ou **caso a cláusula contratual em que se baseie for posteriormente declarada nula, configurar-se-á hipótese de engano justificável**, excludente apta a afastar a incidência da sanção civil de repetição em dobro do indébito.

5. Nesse quadro, à luz das supracitadas premissas, submeto a seguinte tese objetiva aos demais membros da Corte Especial: **a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, revela-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.**

Ademais, a fim de evitar surpresas, em respeito à segurança jurídica, **adiro à proposta de modulação de efeitos decisórios, formulada pelo eminente Ministro Herman Benjamin, para que a exegese ora fixada seja aplicada a pedidos de devolução em dobro relacionados a contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias somente a partir da conclusão do presente julgamento.**

6. Na hipótese concreta dos autos, como dito, o autor ajuizou, em 15.08.2011, ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com pedido de repetição do indébito, afirmando que a companhia telefônica, nas faturas emitidas a partir de janeiro de 2006, inserira, de forma arbitrária e sem comunicação, a cobrança de serviço não solicitado, bem como substituíra a "assinatura básica residencial" (equivalente ao "plano básico em minutos da ANATEL", com franquia mensal de 200 minutos) pela "franquia mensal 800 minutos e plano conta completa", sem contratação prévia.

Na inicial, especificou números de protocolos de reclamações junto à companhia telefônica, alegando que:

> Em vista de tais fatos, o autor entrou em contato diversas vezes com o serviço de atendimento ao consumidor, 0800, a fim de requerer a retirada de tal valor de sua conta telefônica, sem obter, contudo, qualquer êxito. Muito pelo contrário, as contas telefônicas dos meses seguintes continuaram a chegar à residência do autor com o valor do serviço não contratado nem solicitado, não havendo, assim, qualquer enquadramento legal ou contratual autorizador.
> Como as ligações realizadas para o serviço de atendimento ao consumidor 0800 não surtiram efeito, visto que as cobranças não eram canceladas, o autor dirigiu-se diversas vezes até o ponto comercial da empresa ré para requerer a retirada do valor ilegal, o que também não resolveu o problema.
> Tamanho desrespeito pelo consumidor já vem ocorrendo há mais de 2

> (dois) anos, obrigando o requerente a ligar todos os meses para solicitar a retirada do serviço ilegal que ele nunca solicitou nem contratou, e, mesmo assim, a empresa ré, continua a realizar a cobrança.
> Tendo em vista toda a situação ocorrida, a qual ainda perdura, o autor já desistiu de tentar resolver o problema amigavelmente, visto que até a presente data a empresa ré nunca efetuou as devoluções dos valores conforme haviam acordado no serviço de atendimento ao consumidor 0800, e muito menos retirou o serviço.
> Além do mais, quando o autor realizava as reclamações, as atendentes do serviço 0800 da empresa ré referiam que seria enviado uma nova conta com o valor correto, contudo, essas contas nunca foram remetidas para o autor, que acabava efetuando os pagamentos das contas incorretas para não ser bloqueado o seu telefone. (fls. 5/6)

Por fim, o autor requereu: (i) antecipação da tutela jurisdicional, determinando-se que a companhia telefônica emitisse faturas sem a cobrança indevida; (ii) o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança efetuada; (iii) a inversão do ônus da prova; (iv) que a ré fosse obrigada a juntar aos autos as faturas telefônicas dos últimos cinco anos, com as discriminações dos valores cobrados e pagos; (v) **a devolução em dobro das cobranças indevidas**; e (vi) o pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação (fls. 64/80), a ré defendeu: (i) a regularidade das cobranças, pois os serviços prestados teriam sido solicitados via call center; (ii) que, administrativamente, as objeções do autor foram analisadas e julgadas improcedentes (fl. 71); (iii) que, em não concordando com os valores cobrados, o autor detinha a opção de não efetivar o pagamento até ver solucionada a lide, "mas optou por pagar espontaneamente os valores, certamente por saber serem devidos"; e (iv) a inexistência de má-fé de sua parte (a ensejar eventual repetição em dobro), uma vez que os serviços cobrados foram, efetivamente, prestados, ainda que haja controvérsia sobre sua contratação.

O magistrado de piso, ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral reconhecendo a irregularidade das cobranças e determinando a repetição em dobro, assim consignou:

> Extrai-se das contas telefônicas acostadas com a inicial, que a demandada, efetivamente, realizava a cobrança dos serviços: Comodidade Pacote de Serviços Inteligentes 2, Franquia Mensal 800 Minutos e Plano Conta Completa.
> Considerando que a parte autora nega a existência da solicitação dos referidos serviços, incumbe à Companhia Telefônica comprovar a legitimidade da cobrança, demonstrando inequivocamente a manifestação de vontade do consumidor no sentido de obter os serviços em questão e arcar com os respectivos custos. É evidente que, ao consumidor, resta inviável a prova de que não solicitou (prova negativa), o que faz incidir a conclusão acima referida.
> Todavia, compulsando os autos, nenhum documento foi trazido pela requerida para corroborar as alegações tecidas. Deste modo, não se pode

> concluir que parte autora tenha contratado os serviços da demandada, na forma alegada.
> Outrossim, compulsando os extratos internos juntados com a contestação, tenho que não se prestam à finalidade pretendida, já que não se pode concluir das informações ali contidas que parte autora tenha contratado os serviços da demandada, na forma alegada.
> Embora sabido que a contratação desses serviços, geralmente ocorre via telefone, a demandada ao alegar que a autora aderiu aos serviços cobrados deve comprovar que, efetivamente, houve a contratação ou adesão pelo cliente. No entanto, analisando-se os autos, nada foi colacionado capaz de demonstrar que a autora, efetivamente, solicitou e aderiu os serviços cobrados.
> Desta forma, reconheço como indevida a cobrança dos serviços: Comodidade Pacote de Serviços Inteligentes 2, Franquia Mensal 800 Minutos e Plano Conta Completa, devendo a demandada efetuar devida restituição, dos valores indevidamente pagos, em dobro, desde janeiro de 2006.
> (...)
> (...) quem deveria fiscalizar os falhos serviços prestados pelas concessionárias, ou seja, as Agências Reguladoras, tem se omitido nesta função, permitindo que serviços não solicitados sejam incluídos indevidamente nas faturas de consumo.
> Seria, na verdade, muito mais racional, que se atendesse à boa-fé objetiva, e as companhias telefônicas obtivessem prova segura da solicitação os serviços, e, em caso contrário, restituíssem os valores indevidos, mediante simples crédito na fatura, evitando esta verdadeira avalanche de processos judiciais. Porém, lamentavelmente, não tem sido essa a realidade, optando-se por onerar de maneira impressionante as estruturas do Poder Judiciário, possivelmente acreditando-se que com isso ele realmente não possa mais cumprir com a sua tarefa precípua de limitar os abusos.
> (...) (fls. 185/186)

O Tribunal de origem, ao julgar as apelações das partes, manteve a condenação da companhia telefônica à devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas, nos seguintes termos:

> Não há dúvidas de que a relação estabelecida entre a operadora de telefonia e a cliente autora é de consumo, devendo ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme já exposto acima. Por essa razão, não há como cogitar reconhecer a não aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
> (...)
> A lei é clara e não deixa qualquer dúvida.
> Obviamente que a aplicação desta norma exige que exista relação de consumo e que efetivamente tenha ocorrido o pagamento pelo consumidor, bem como não se trate de hipótese de engano justificável.
> Cumpre destacar que, em se tratando de relação consumerista, não há exigência alguma no sentido de que o consumidor comprove existência de má-fé por parte do fornecedor do serviço ao efetuar a cobrança indevida. (fl. 326)

No recurso especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, a companhia telefônica apontou, entre outros, violação do artigo 42 do CDC, sustentando que: (i) a incidência da sanção de repetição em dobro não se revela possível quando inexistente má-fé do fornecedor; (ii) nunca tivera a intenção de apropriar-se dos valores cobrados; e (iii) não houve cobrança vexatória, *"pois os descontos foram todos efetuados diretamente na conta bancária do autor, por descuido, também da parte autora que só percebeu anos depois"* (fl. 393).

Diante desse cenário, e dos fundamentos até aqui expostos, penso que, **diferentemente do provimento exarado pela Quarta Turma**, a insurgência especial da fornecedora não comportava acolhida, pois suficientes os indícios de má-fé (conduta contrária à boa-fé objetiva) trazidos pelo autor na inicial, no sentido da existência de reiteradas reclamações, por mais de dois anos, sobre a irregularidade das cobranças, fato que foi, expressamente, confirmado pela ré na contestação, que – consoante assente pelo magistrado de piso – não juntara documentos aptos a demonstrar eventual razoabilidade do seu equívoco, limitando-se a afirmar que ocorrera contratação via *call center*, sem apresentar as gravações respectivas.

Ademais, também causa estranheza o fato de as cobranças somente terem sido canceladas após o ajuizamento da demanda. Com efeito, ainda que houvesse prévia contratação (o que não foi provado pela fornecedora), a reclamação da consumidora deveria ter ensejado a imediata regularização da cobrança, com a exclusão dos serviços repudiados, o que, de forma flagrantemente abusiva - e, no mínimo, descuidada -, não ocorreu.

7. Ante o exposto, ouso divergir da eminente e culta relatora na parte da fundamentação, pois busquei posição que penso mais consentânea com o equilíbrio existente entre as teses das duas Seções — como procurei demonstrar, em aparente conflito —, ao estabelecer que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, revela-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ser observadas as premissas delineadas no item 4.4 do presente voto, mas a acompanho na conclusão, provendo os embargos de divergência a fim de negar provimento ao recurso especial da companhia telefônica, mantendo a sua condenação ao pagamento da sanção civil.

Por fim, adiro à proposta do eminente Ministro Herman Benjamin de modulação de efeitos da exegese conferida ao parágrafo único do artigo 42 do CDC, no que diz respeito a pedidos de devolução em dobro relacionados a contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, cuja incidência dar-se-á somente a partir da conclusão do presente julgamento.

É como voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9)
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE : PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS : FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539
ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO : BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS : TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227
CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494
ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

VOTO-VOGAL

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI:

Cuida-se de embargos de divergência opostos por PEDRO LUGOCH, com fundamento nos arts. 496, VIII, 508 e 546 do CPC/73 e art. 266 do RISTJ, em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do STJ, assim ementado:

> AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. NÃO PROVIMENTO.
> 1. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF.
> 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
> 3. Não cabe a adição de teses não expostas no recurso especial em sede de agravo regimental. Precedente.
> 4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Enunciado 182 da Súmula do STJ).
> 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

Na sessão da Corte Especial de 02/05/2018, a i. Min. Relatora apresentou voto em que conhece e dá provimento aos embargos de divergência. Após, o Min. Herman Benjamin pediu vistas dos autos.

Na sessão de julgamento de 20/02/2019, o i. Min. Herman Benjamin proferiu voto no sentido de acompanhar a i. Ministra relatora para conhecer e dar provimento aos embargos de divergência, com uma proposta de modulação dos efeitos do presente julgamento.

Após essa manifestação, pediu vistas o i. Min. Luís Felipe Salomão, o qual, em 18/12/2019, proferiu voto, mesmo que acompanhando no resultado, diverge da Ministra relatora na fundamentação e, ainda, apresenta uma tentativa de harmonização dos entendimentos entre a Primeira e a Segunda Seção deste STJ.

É o relatório.

1. DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVISTA NO CDC

O propósito recursal dos embargos de divergência em julgamento consiste em determinar a necessidade de comprovação de má-fé pela operadora de telefonia por cobranças abusivas de serviços não contratados ou não autorizados para que ocorra a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Desde já, acompanho a i. Ministra relatora quanto ao conhecimento dos embargos de divergência, pois a similitude fática entre o julgamento embargado e os acórdãos paradigmas é patente, conforme se comprova pelas ementas dos acórdãos paradigmas:

> ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 182/STJ. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. PRAZOS GERAIS DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO FIXADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 412/STJ.

(...)
2. O STJ firmou o entendimento de que basta a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor na cobrança indevida de serviços públicos concedidos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 143.622/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.6.2012; AgRg no Ag 1.417.605/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 2.2.2012; AgRg no Resp 1.117.014/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.2.2010; e REsp 1.085.947/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 12.11.2008.
(...)
6. Agravo Regimental conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
(AgRg no ARESp 262.212/RS, Relator o Ministro Herman Benjamin, DJe de 07/03/2013)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO AO ART. 42 DO CDC. SÚMULA 7/STJ.
1. "O STJ firmou o entendimento de que basta a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor na cobrança indevida de serviços públicos concedidos" (AgRg no AREsp 262.212/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2013).
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 371.431/MS, Relator o Ministro Sérgio Kukina, DJe de 22/10/2013)

Trata-se exatamente da mesma discussão, a necessidade da comprovação de má-fé para a repetição de indébito, em dobro, nos termos do CDC.

Devemos considerar esse momento de extrema importância para a jurisprudência do STJ, pois nos permite revisitar um tema altamente relevante para a defesa do consumidor e, ainda, realizar uma eventual correção de rumo, no sentido de conferir uma maior efetividade às normas jurídicas em vigor.

Não se desconhece que este assunto se encontra atualmente pacificado no âmbito das Turmas da Segunda Seção, que sempre exigiram a

comprovação da má-fé por parte do fornecedor para que ocorre a devolução em dobro prevista no mencionado dispositivo da legislação consumerista. Apenas como exemplos, citem-se apenas dois, sob minha própria relatoria, que reafirmam essa posição comum à Segunda Seção do STJ, quais sejam:

> A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. (...)
> (REsp 1032952/SP, Terceira Turma, DJe 26/03/2009)

> PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor. 2. Agravo não provido.
> (AgRg no REsp 1441094/PB, Terceira Turma, DJe 01/09/2014)

É certo que os julgamentos mencionados acima não abordavam serviços de telefonia, mas indubitavelmente discorriam sobre relações de consumo e, assim, atraíam a aplicação do CDC.

Mencionou-se acima que este momento era de grande importância, pois obrigou-nos a uma reflexão sobre a formação desse entendimento jurisprudencial comum às Turma da Segunda Seção. Por isso, é necessário fazer uma breve reflexão sobre os precedentes das Turmas que compõem a Segunda Seção.

Nos julgamentos acima mencionados, entre os precedentes citados está o REsp 401.589/RJ (Quarta Turma, DJ 04/10/2004, p. 303), julgado no ano de 2004, assim ementado:

> PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.
> 1. Não há falar em violação ao art. 535 do CPC, se o acórdão recorrido, ao solucionar a controvérsia, longe de ser omisso, bem delineia as questões a ele submetidas, mesmo porque não carrega a pecha de omisso, pois o órgão judicial,

> para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
> 2. Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, a TR pode ser utilizada como índice de correção monetária dos débitos, desde que previsto contratualmente, como na espécie (súmula 295/STJ).
> 3. A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples. Precedentes.
> 4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
> (REsp 401.589/RJ, Quarta Turma, DJ 04/10/2004, p. 303)

No voto condutor, encontra-se a seguinte fundamentação, com menção a outro julgamento, o REsp 505.734/MA:

> Outrossim, a irresignação da recorrente atinente à restituição em dobro de eventual indébito também merece guarida. Com efeito, a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé/culpa do credor, o que, in casu, não está evidenciado. Em hipótese semelhante decidiu a colenda Terceira Turma, quando do julgamento do Resp 505734/MA, DJ 23.06.2003, em acórdão da relatoria do Min. Carlos Alberto Menezes Direito (...)

Por sua vez, o voto condutor do julgamento do REsp 505.734/MA (Terceira Turma, DJ 23/06/2003), que parece ser o primeiro julgamento acerca do tema na Terceira Turma, afirma o seguinte:

> Indica, ainda, afronta ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor alegando que "afronta a esse dispositivo legal ocorreu na medida em que não houve pagamento e o recorrente foi condenado a devolver um indevido inexistente e em dobro", invocando a Súmula nº 159 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que, embora houvesse cobrança excessiva, sem a má-fé não cabe o pagamento em dobro. O Acórdão recorrido afirmou ser "fato incontroverso que a cobrança e o pagamento dos valores apurados como indevidos e em excesso às fls. do Laudo Pericial, foram efetivamente realizados antes mesmo do ajuizamento da ação de execução. Esta serviu apenas para que ficasse constatado nos autos dos embargos do devedor a ela opostos, o alegado indébito". Assim, o Acórdão recorrido confirma que houve a cobrança e o pagamento indevido, o que justifica a repetição. Esta Corte tem precedente no sentido de que se admite a repetição do indébito "de valores pagos em virtude de cláusulas ilegais, em razão do princípio que veda o enriquecimento injustificado do credor" (REsp nº 453.782/RS, Relator o Senhor Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 24/2/03; do mesmo Relator: REsp nº 79.448/RS, DJ de 10/6/02). Afirma o recorrente que somente caberia a devolução em dobro se efetuada a cobrança com má-fé. E nesse flanco, a meu sentir, tem razão o Banco recorrente. Para a repetição em dobro deve haver a prova de que o

> credor agiu com má- fé. Somente se há comportamento malicioso do autor, agindo de forma consciente, ou seja, sabendo que não tem o direito pretendido, é possível exigir-se a repetição em dobro. E, no caso, não há mesmo como configurar que tenha o Banco credor assim agido. Como sabido, embora diversa a regra daquela do art. 1.531 do Código Civil, tenho que o requisito da má-fé também está presente no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Em matéria de cobrança decorrente de financiamento, que suscita controvérsia nos Tribunais, não se pode identificar, a meu sentir, nem a má-fé nem mesmo dolo ou culpa. Tanto isso é verdade, que persiste ainda hoje, submetida ao crivo do Colendo Supremo Tribunal Federal, a questão da incidência do Código de Defesa do Consumidor nas operações bancárias, embora, depois de oscilação, tenha sido assentado o tema nesta Corte. Daí que merece conhecido e provido, em parte, o especial neste aspecto para afastar a repetição em dobro. (Grifou-se)

Nessa assentada, a Terceira Turma não apenas entendeu que o requisito da comprovação da má-fé está previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, como também considerou o fato de, à época do julgamento – no ano de 2003 – ainda estar pendente de julgamento sobre a constitucionalidade da aplicação da legislação de defesa do consumidor às instituições financeiras pelo Supremo Tribunal Federal.

Essa questão foi apenas terminantemente pacificada no ano de 2006, com o julgamento ADI 2591, nos termos da ementa abaixo:

> EMENTA: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3º, § 2º, DO CDC]. MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. 1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito. 3. O preceito veiculado pelo art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado em coerência com a Constituição, o que importa em que o custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras na exploração da intermediação de dinheiro na economia estejam excluídas da sua abrangência. 4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a perspectiva macroeconômica, da taxa base de juros praticável no mercado financeiro. 5. O

> Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever-poder de fiscalizar as instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das taxas de juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro na economia. 6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete às normas do Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do custo das operações ativas e da remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na economia, sem prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisão, pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso, de eventual abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorções na composição contratual da taxa de juros. ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR EXCLUSIVAMENTE PARA A REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO. 7. O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição do Brasil consubstancia norma-objetivo que estabelece os fins a serem perseguidos pelo sistema financeiro nacional, a promoção do desenvolvimento equilibrado do País e a realização dos interesses da coletividade. 8. A exigência de lei complementar veiculada pelo art. 192 da Constituição abrange exclusivamente a regulamentação da estrutura do sistema financeiro. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART. 4º, VIII, DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA MATÉRIA. 9. O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa --- a chamada capacidade normativa de conjuntura --- no exercício da qual lhe incumbe regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no plano do sistema financeiro. 10. Tudo o quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto de regulação por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário Nacional. 11. A produção de atos normativos pelo Conselho Monetário Nacional, quando não respeitem ao funcionamento das instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando afronta à legalidade. (ADI 2591, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2006, DJ 29-09-2006 PP-00031 EMENT VOL-02249-02 PP-00142 RTJ VOL-00199-02 PP-00481)

Portanto, tem-se uma interessante situação que, mudou-se um pressuposto de aplicação jurisprudencial de uma norma jurídica, mas não se alterou seu resultado último. As Terceira e Quarta Turmas do STJ continuaram a exigir a comprovação da má-fé para a devolução em dobro, que, em realidade, é um requisito previsto apenas na legislação civil, mas totalmente ausente na literalidade da lei de defesa do consumidor, como será discutido a seguir.

Não à toa que doutrinadores, como Cláudia Lima Marques, afirmarem que, em mais de 20 (vinte) anos de vigência do CDC o disposto no art. 42,

parágrafo único, tenha alcançado relativa ou pouca efetividade (MARQUES, C.L.; BENJAMIN, A.H.V.; e MIRAGEM, B. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 5ª ed, 2016, p. 1099).

Levantando-se, assim, a influência dos precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ, cumpre-nos refazer uma cuidadosa interpretação do CDC, no que diz respeito à repetição de valores cobrados indevidamente pelos fornecedores. Essa é a redação do dispositivo legal em discussão:

> CDC
> Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
> Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Da leitura do dispositivo, portanto, podemos concluir que os requisitos para a ocorrência de uma repetição de indébito, em dobro, são: (i) a existência de uma relação de consumo; (ii) a ocorrência de uma cobrança indevida; (iii) o pagamento pelo consumidor do valor indevido; e (iv) ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

A existência da relação de consumo é pressuposto fundamental para a incidência do CDC. Sem ela, as regras aplicáveis seriam aquelas prevista na legislação civil, em que há a necessidade de comprovação da má-fé para a repetição em dobro.

Configura-se cobrança indevida toda vez que ao consumidor é apresentado uma fatura em que constam valores a maior ou serviços não contratados, bem como quando – muito comum por parte das instituições financeiras – os valores são retirados diretamente da conta corrente dos consumidores. A questão do pagamento pelo consumidor é um requisito básico,

pois não se pode repetir aquilo que não se pagou.

O último requisito diz respeito à inexistência de "engano justificável", quer dizer que, se o fornecedor provar que a cobrança indevida ocorreu de forma justificada, o consumidor fará jus apenas a devolução do valor que pagou em excesso ao fornecedor. Esse requisito, como é possível perceber, é o mais controverso por potencialmente confundir conceitos e merecerá maiores comentários a seguir.

A doutrina mais balizada sobre o assunto é unânime em afastar o elemento anímico (culpa ou dolo) para a configuração da repetição em dobro do valor cobrado indevidamente pelos fornecedores.

Na opinião de Flávio Tartuce, "*a exigência de prova de má-fé ou culpa do credor representa a incidência de um modelo subjetivo de responsabilidade, totalmente distante do modelo objetivo adotado do CDC, que dispensa o elemento culposo*" (Manual de direito do consumidor. Rio de Janeiro: Método, 5ª ed., 2016, p. 506).

Por sua vez, Bruno Miragem afirma o seguinte, ao analisar o art. 42, parágrafo único, do CDC:

> É de se perceber que não se exige na norma em destaque, a existência de culpa do fornecedor pelo equívoco da cobrança. Trata-se, pois, de espécie de imputação objetiva, pela qual o fornecedor responde independentemente de ter agido ou não com culpa ou dolo. (...) Não se pode concordar, assim, com o entendimento que condiciona a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, à demonstração (em regra, pelo consumidor) da presença de conduta reprovável do fornecedor (dolo ou culpa), uma vez que esta interpretação coloca em evidente contrariedade ao disposto no texto da norma. (Curso de Direito do Consumidor. São Paulo: RT, 2ª ed., 2010, p. 209-210)

No mesmo sentido, a professora Cláudia Lima Marque afirma que, a princípio, toda cobrança a maior do consumidor é indevida, devendo ocorrer a

repetição em dobro, exceto se o fornecedor justificar o engano na cobrança, conforme sua lição a seguir:

> A devolução simples do cobrado indevidamente é para casos de erros escusáveis dos contratos entre iguais, dois civis ou dois empresários, e está prevista no CC/2002. No sistema do CDC, todo engano na cobrança de consumo é, em princípio, injustificável, mesmo o baseado em cláusulas abusivas inseridas no contrato de adesão, ex vi o diposto no parágrafo único do art. 42. Cabe ao fornecedor provar que seu engano na cobrança, no caso concreto, foi justificado. (MARQUES, C.L.; BENJAMIN, A.H.V.; e MIRAGEM, B. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 5ª ed, 2016, p. 1099).

Por sua vez, o professor Leonardo de Faria Beraldo afirma que, com a referência à expressão "engano justificável", neste ponto, o CDC se afasta da responsabilidade objetiva para adotar uma regra de culpa presumida do fornecedor, a quem caberá provar que não agiu com má-fé na cobrança de valores indevidos junto ao consumidor (*A vulnerabilidade do consumidor e a devolução em dobra da cobrança indevidamente paga*. In: LIMA, T.M.M.; SÁ, M.F.F.; MOUREIRA, D.L. Autonomia e vulnerabilidade. Belo Horizonte: Arraes, 2017).

Dessa forma, feita essa breve referência doutrinária – reconhecendo a relatoria de julgamentos no sentido de exigir a comprovação pelo consumidor da má-fé do fornecedor – entendo que a orientação das Turmas da Segunda Seção deve ser alterada por dois motivos essenciais e, neste ponto, ouso divergir da proposta de conciliação apresentada pelo bem lançado voto do i. Min. Luís Felipe Salomão.

Primeiro, o requisito da comprovação da má-fé não consta do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem em qualquer outro dispositivo da legislação consumerista. A parte final da mencionada regra – "salvo hipótese de engano justificável" – não pode ser compreendida como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor.

Ademais, em segundo lugar, por ser a parte vulnerável e hipossuficiente da relação de consumo, não é justo impor ao consumidor o dever de provar que o valor indevido foi cobrado de modo culposo. Lembre-se que, por definição, o consumidor é a parte vulnerável de toda e qualquer relação de consumo, como bem mencionou o Min. Herman Benjamin, "*a vulnerabilidade é um traço universal de todos os consumidores, ricos ou pobres, educados ou ignorantes, crédulos ou espertos*" (In: GRINOVER, Ada Pelegrini e outros. Código de defesa do consumidor comentado. São Paulo: Forense, 1993, p. 224-225).

Em realidade, deve ocorrer exatamente o contrário, ao reconhecer o caráter hipossuficiente do consumidor: o fornecedor tem a possibilidade de comprovar que o erro foi justificável e, assim, ser afastada a penalidade civil da repetição em dobro.

Nesse sentido, como bem mencionado pelo professor Leonardo de Faria Beraldo, o "engano justificável" previsto no dispositivo legal em discussão consiste em uma excludente de culpabilidade no que toca ao pleito da devolução em dobro, sendo que nas hipóteses em que houver essa justificativa caberá apenas a devolução simples dos valores indevidamente cobrados.

Com isso, abandona-se qualquer perquirição em torno da presença ou não da boa-fé objetiva e subjetiva ou de qual o correto contorno da má-fé do fornecedor para ensejar a devolução em dobro e, assim, as pretensões passam a ser analisadas sob uma luz muito simples, transparente e consentânea com o direito de defesa do consumidor.

2. DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS

Quanto à modulação dos efeitos deste julgamento, o i. Min. Herman Benjamin propõe, com fundamento no art. 927, § 3º, do CPC/2015, que os efeitos deste julgamento – qual seja, o entendimento segundo o qual repetição em dobro não depende da demonstração pelo consumidor de má-fé do fornecedor – para seja aplicada somente aos valores pagos indevidamente pelos consumidores após a conclusão deste julgamento.

Nos termos do mencionado dispositivo legal, a modulação do julgamento pode ocorrer "no interesse social e no da segurança jurídica". No entanto, parece-me na hipótese em julgamento não há "interesse social" a ser protegido.

Veja-se que, por força de lei, o consumidor é reconhecidamente a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4º, I, do CDC) e que a defesa do consumidor deve ter como princípio a "*harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores*" (art. 4º, III, do CDC).

Ademais, o CDC dispõe que um dos direitos básicos do consumidor é "*a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos*" (art. 6º, VI, do CDC). Também não podemos nos olvidar que a defesa do consumidor é um dos princípios sobre os quais se fundamenta a ordem econômica brasileira, nos termos do art. 170, V, da Constituição Federal.

Dessa forma, rogando todas as vênias ao Min. Herman Benjamin, não se mostra possível a modulação proposta, nos termos do art. 927, § 3º, do

CPC/2015, pois não há interesse social em reduzir a proteção do consumidor. Como mencionado acima, o consumidor é a parte vulnerável e hipossuficiente na relação de consumo e merece toda a salvaguarda jurídica que lhe é oferecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, que se orienta decididamente para sua proteção e defesa.

3. DAS CONCLUSÕES

Forte nessas razões, com as razões adicionais expostas acima e rogando todas as vênias à divergência, acompanho a i. Ministra relatora, para CONHECER e DAR PROVIMENTO aos embargos de divergência, sem modulação dos efeitos deste julgamento.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2013/0355826-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EREsp 1.413.542 / RS**

Números Origem: 00024664120118210124 00382183920138217000 11100012910 12111794201382170000 12411100012910 24664120118210124 382183920138217000 70052756772 70053135935 70053964904

PAUTA: 07/08/2019 JULGADO: 07/08/2019

Relatora
Exma. Sra. Ministra **MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro : **BENEDITO GONÇALVES**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE	:	PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539 ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO	:	BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS	:	TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227 CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494 ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por Dano Moral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão acompanhando o voto da Sra. Ministra Relatora, mas com fundamentação diversa, a manifestação do Sr. Ministro Herman Benjamin incorporando novos fundamentos ao seu voto, ao qual acompanhou o Sr. Ministro João Otávio de Noronha, o aditamento ao voto da Sra. Ministra Relatora para não modular os efeitos da decisão e o voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi acompanhando integralmente o voto da Sra. Ministra Relatora, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Raul Araújo.

Aguardam os Srs. Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Felix Fischer e Humberto Martins.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Licenciado o Sr. Ministro Felix Fischer.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2013/0355826-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EREsp 1.413.542 / RS**

Números Origem: 00024664120118210124 00382183920138217000 11100012910 12111794201382170000 12411100012910 24664120118210124 382183920138217000 70052756772 70053135935 70053964904

PAUTA: 20/11/2019 JULGADO: 20/11/2019

Relatora
Exma. Sra. Ministra **MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro : **BENEDITO GONÇALVES**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE	:	PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539 ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO	:	BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS	:	TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227 CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494 ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por Dano Moral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado por indicação do Sr. Ministro Raul Araújo.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**
EMBARGANTE	:	PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539 ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO	:	BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS	:	TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227 CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494 ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO RAUL ARAÚJO:

A controvérsia cinge-se a dirimir a divergência jurisprudencial entre julgados das Turmas que compõem as Primeira e Segunda Seções do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no **parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor**, que prevê sanção civil ao fornecedor, consistente na **devolução em dobro** dos valores cobrados indevidamente de consumidor, salvo quando houver engano justificável.

O dissídio pretoriano parece configurado, pois, de um lado, há precedentes firmados pelas Turmas de Direito Privado, segundo os quais, para fins de incidência da referida sanção civil, é necessária a comprovação da má-fé do credor na cobrança indevida e, de outro lado, há precedentes das Turmas de Direito Público que salientam depender a devolução em dobro do indébito apenas da configuração da culpa.

Por ocasião do voto que proferi, na condição de Relator, nos **EAREsp 622.897/RS**, bem como do voto-vista que prolatei nos **EAREsp 676.608/RS**, tive a oportunidade de lançar ponderações no sentido de que a aplicação da sanção civil, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é justificável quando ficarem **configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor**.

De fato, a questão da forma de devolução de valores pagos indevidamente, e da necessidade de comprovação da má-fé para justificá-la, não é nova.

À época da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, vigia no ordenamento jurídico brasileiro o art. 1.531 do Código Civil de 1916, que assim dispunha:

> *Art. 1.531. **Aquele que demandar por dívida já paga**, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, **ficará obrigado a pagar o devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado** e, no segundo, o equivalente do que lhe exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o direito, decair da ação.*

A mesma norma foi replicada no Código Civil de 2002, cujo art. 940 assim dispõe:

> *Art. 940.* ***Aquele que demandar por dívida já paga,*** *no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido,* ***ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado*** *e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.*

Embora **nem o dispositivo do revogado Código Civil de 1916, tampouco o do Código Civil de 2002 (assim como o CDC), refiram-se à necessidade de comprovação de má-fé para sua aplicação,** o entendimento prevalente na doutrina cedo consolidou-se no sentido de **exigir-se a comprovação da má-fé** para ter lugar a devolução em dobro.

CLÓVIS BEVILÁQUA, na edição de 1939 dos seus *Comentários ao Código Civil de 1916*, já definia a norma contida no art. 1.531 nos seguintes termos:

> *Outra pena civil imposta ao que tenta extorquir o alheio, sob o color de cobrar dívidas.*
> (Código Civil Comentado, 4ª ed., Livraria Francisco Alves, Rio de Janeiro-RJ, 1939, vol. V, p. 313.)

Trata-se a devolução em dobro, portanto, de **sanção civil**, cabível, por óbvio, nas hipóteses de má-fé do agente.

Nessa senda, a matéria veio a ser sumulada pelo colendo **Supremo Tribunal Federal**, em 1963, com a edição da **Súmula 159**:

> *Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art 1.531 do Código Civil.*

De um dos precedentes que justificaram a edição da súmula - o Recurso Extraordinário 48.986 -, extrai-se o seguinte trecho do voto do Relator, nobre **Ministro Ribeiro da Costa**:

> *A aplicação da pena prevista no art. 1.531 do Código Civil, deve filiar-se a* ***prática de ato ilícito*** *que exterioriza verdadeira extorsão.*
> *Eis as palavras de* ***Clóvis****: outra pena civil imposta ao que tenta extorquir o alheio, sob color de cobrar dívidas (C. Civil - Comentado - 3ª ed. vol. V, pag. 313).*
> ***O entendimento de que a lei não exige dolo para a aplicação é, data venia, superficial, abstraindo o sentido da ilicitude do fato, de que é imanente a malícia, o propósito de locupletamento com o benefício alheio****.*
> (grifou-se)

A doutrina relacionada ao art. 940 do Código Civil de 2002 segue a mesma linha:

> *A questão mais relevante neste dispositivo é a que diz respeito ao* ***elemento subjetivo do credor****. Bastará* ***mero engano ou descuido****, por*

> *parte do credor, para que tenha lugar a responsabilidade pelo excesso de pedido, simples culpa, ou terá que haver a malícia, verdadeira má-fé? A questão já estava sumulada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 159), quando a matéria era ainda da sua competência, no sentido de ser* ***necessária a má-fé:*** *"Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1.531 do Código Civil". O Superior Tribunal de Justiça adotou a mesma orientação (...).*
> (Comentários ao novo Código Civil, vol. XIII: da responsabilidade civil, das preferências e privilégios creditórios. **CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO** e **SÉRGIO CAVALIERI FILHO**. Rio de Janeiro-RJ, Forense, 2007, p. 328)

É importante trazer à colação, por oportuno, **precedente** firmado no âmbito da **colenda Segunda Seção**, em julgamento de **recurso especial repetitivo**, que, ao interpretar a sanção civil prevista no antigo art. 1.531 do Código de 1916 e no atual art. 940 do Código Civil de 2002, concluiu ser imprescindível a comprovação da má-fé do credor para ensejar o pagamento em dobro, em decorrência da cobrança judicial de dívida já adimplida.

Eis a ementa do referido acórdão:

> *RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONSIDEROU INCIDENTES JUROS DE MORA, SOBRE OS VALORES REMANESCENTES A SEREM DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31º DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO APLICOU A SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO DO DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVARA OS VALORES RECEBIDOS.*
> *1. Insurgência dos consorciados excluídos do grupo.*
> *1.1.* ***Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.***
> *1.2.* ***Questão remanescente. Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado.*** *Precedentes.*
> *1.3. Caso concreto.*
> *1.3.1. A Corte estadual considerou evidente a má-fé de um dos autores (à*

> *luz das circunstâncias fáticas constantes dos autos), aplicando-lhe a referida sanção civil e pugnando pela prescindibilidade de ação autônoma ou reconvenção.*
> *1.3.2.Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte acerca da via processual adequada para pleitear a incidência da sanção civil em debate. Ademais, para suplantar a cognição acerca da existência de má-fé do autor especificado, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.*
> *2. Irresignação da administradora do consórcio.*
> *2.1. Voto vencedor (e. Ministro Luis Felipe Salomão). Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio.*
> *2.2. Voto vencido do relator. À luz das peculiaridades do caso concreto - ação ressarcitória ajuizada após o encerramento do grupo consorcial; inexistência de estipulação de termo certo no contrato de adesão; e incidência de previsão normativa, vigente à época, acerca da necessária iniciativa do credor para o recebimento do pagamento (o que caracteriza a dívida como quesível) - afigurar-se-ia cabida a adoção da exegese acerca da incidência dos juros de mora a partir da citação - momento em que ocorrida a obrigatória interpelação do devedor.*
> *3. Recursos especiais desprovidos. Vencido o relator na parte em que dava provimento ao apelo extremo da administradora do consórcio, a fim de determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.*
> (REsp 1.111.270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, **SEGUNDA SEÇÃO**, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/02/2016)

É, portanto, de **salutar tradição** no Direito brasileiro que a devolução em dobro de quantias pagas indevidamente figure como uma **sanção à parte que agiu em desacordo com os princípios que regem essas relações,** entre eles o da boa-fé.

Não cabe aqui a alegação de que a relação de consumo, sendo regida por regra própria, estaria fora do alcance da interpretação, baseada na razoabilidade, dada à legislação civil.

Afinal, a norma contida no Código Civil (tanto no de 1916 como no atual) não faz nenhuma restrição à hipótese de devolução em dobro, e, no entanto, a necessidade de comprovação da má-fé está sumulada desde 1963 pelo STF.

Com mais razão há de se aplicar esse raciocínio na interpretação do Código de Defesa do Consumidor, que também não se refere expressamente à má-fé, mas prevê que, na hipótese de *"engano escusável"*, a devolução em dobro não é cabível.

Ora, ao prever que o *"engano escusável"* afasta a devolução em dobro, o Código de Defesa do Consumidor nada mais faz que prestigiar a boa-fé como elemento das relações contratuais de consumo. Não se pode entender que o CDC dê o mesmo tratamento à conduta deliberada do fornecedor de violar direito dos consumidores e ao comportamento equivocado da sociedade empresária que causa prejuízo à clientela. Em ambas as hipóteses, cabe a restituição do indébito, mas não a sanção da dobra.

Lecionando sobre o tema, **JOÃO BATISTA DE ALMEIDA** anota:

> *(...) o Código [de Defesa do Consumidor] procurou sancionar de forma direta as condutas que afetavam a dignidade do consumidor inadimplente, estabelecendo taxativamente que ele será respeitado em sua integridade física, psicológica e moral, ao impedir sua exposição a ridículo e sua submissão a constrangimento ou ameaça de qualquer tipo ou natureza (art. 42).*
>
> ***Veja-se que a lei impede apenas a cobrança abusiva.*** *O consumidor pode sofrer constrangimentos legais, como protesto do título, penhora, execução, falência, etc. Além disso, pode ser cobrado condignamente em seu trabalho, descanso ou lazer, o que não ocorre, por exemplo, quando o credor telefona para o chefe do consumidor dizendo ser ele mau pagador.*
>
> *O não cumprimento dessa regra importará a aplicação de sanções administrativas ao fornecedor (art. 56), a responsabilização criminal (art. 71) e a* ***imposição das seguintes sanções civis em caso de cobrança de quantia total ou parcialmente indevida: (a) repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do recebido em excesso, acrescida de juros e correção monetária desde o recebimento (art. 42, parágrafo único), e, (b) ocorrendo engano justificável ou boa-fé do credor, permanece a obrigação de restituir o indébito, porém de forma simples, com incidência de juros e atualização monetária (art. 42, parágrafo único, c/c o art. 964, do CC)***.
>
> *(in* A proteção jurídica do consumidor. 5ª ed., 2006. Saraiva, São Paulo, p. 128/129*).*

Como se vê, o doutrinador aponta a devolução em dobro como sanção civil, cabível, portanto, como resposta a uma conduta abusiva do fornecedor, que deliberadamente cobrou o que não lhe era devido.

Logo, é necessário, para afastar a ressalva legal expressa de *"hipótese de engano justificável"*, que se comprove ou, pelas circunstâncias, se possa claramente identificar, no caso

concreto, a má-fé do fornecedor para ser reconhecido o direito à devolução em dobro do valor pago, conforme têm reiteradamente decidido as Turmas desta Corte que compõem a eg. Segunda Seção e se entendeu no v. acórdão embargado.

De fato, no âmbito da eg. **Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça**, tem prevalecido o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para justificar a devolução em dobro dos valores recebidos indevidamente. Assim o demonstram os acórdãos a seguir:

> *PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. **CDC. APLICAÇÃO.** IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA.*
> *1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.*
> *2. **A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.***
> *3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.*
> *4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).*
> *5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados.*
> *6. Agravo interno a que se nega provimento.*
> (AgInt no REsp 1.502.471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, **QUARTA TURMA**, julgado em 29/10/2019, DJe de 05/11/2019)

> *RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. **DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.***

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei nº 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4º, IX, e 9º).
3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução CMN nº 3.919/2010, que manteve a mesma essência do regramento anterior (Resolução CMN nº 3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora.
4. A limitação prevista tanto na Resolução CMN nº 3.518/2007 quanto na Resolução CMN nº 3.919/2010 somente se aplica às pessoas naturais. As tarifas relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário.
5. Hipótese em que a instituição financeira demandada não demonstrou a existência de prévia pactuação para fins de cobrança da Tarifa de Manutenção de Título Vencido, decorrendo daí a sua ilegalidade.
6. ***A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.***
7. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1.626.275/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, **TERCEIRA TURMA**, julgado em 04/12/2018, DJe de 07/12/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
*1. N****os termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvida para apreciação".*** *Precedentes.*

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, **QUARTA TURMA**, julgado em 17/04/2018, DJe de 23/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. 1. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRECEDENTES. 2. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. ***IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. SÚMULA 83 DO STJ. 3. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ****. 4. ALEGADA OFENSA AO ART. 475-B, § 1º, DO CPC/1973. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.*
1. O entendimento das Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte é no sentido de que o prazo prescricional da ação ordinária por cobrança indevida de valores referentes a serviços de telefonia não contratados, como no caso dos autos, é o previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, ou seja, 3 anos.
2. ***Outrossim, a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior entende ser impossível a restituição em dobro do indébito sem a prova de que a instituição financeira tenha agido de má-fé****.*
3. A análise quanto à ocorrência do dano moral demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta Corte, ante o óbice constante do enunciado sumular n. 7/STJ.
4. O art. 475-B, § 1º, do CPC/1973, tido por violado no apelo nobre, não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco cuidou o agravante de prequestioná-lo em embargos declaratórios, faltando, desse modo, o indispensável prequestionamento da matéria. Assim, aplicáveis os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 708.688/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, **TERCEIRA TURMA**, julgado em 19/05/2016, DJe de 31/05/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA EM DIAS ÚTEIS. SÚMULA 284/STF. ***RESTITUIÇÃO SIMPLES AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SUMULA 83/STJ. REEXAME. SUMULA 7/STJ****. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.*
1. A mera alegação de violação à legislação federal, desacompanhada

> *de argumentação jurídica pertinente e apta a demonstrar em que medida houve a alegada vulneração atrai a incidência da Súmula 284/STF e impede o conhecimento do recurso.*
> *2.* ***A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes****.*
> *3. O Tribunal de origem entendeu como não configurada a má-fé da parte credora, afastando a devolução em dobro do indébito. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria nova análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.*
> *4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.*
> *Incide na espécie a Súmula 182/STJ.*
> *5. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei.*
> *6. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa.*
> (AgRg no AgRg no AREsp 731.339/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, **QUARTA TURMA**, julgado em 03/05/2016, DJe de 06/05/2016)

No âmbito deste julgamento, em apertada síntese, a **Relatora**, eminente **Ministra Maria Thereza de Assis Moura**, dando **provimento aos embargos de divergência**, deliberou no sentido de que, para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, "*é desnecessária a comprovação da má-fé do credor, bastando a culpa*", no que foi acompanhada integralmente pela **em. Ministra Nancy Andrighi**.

O **em. Ministro Herman Benjamin**, em voto-vista, entendeu pelo **provimento** dos embargos de divergência, concluindo ser necessário: "*a) estabelecer que a devolução em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) ocorre quando o comportamento do fornecedor for doloso ou culposo; b) modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos que não decorram da prestação de serviço público pagos após a data da conclusão do presente julgamento* (em relação a julgados da Segunda Seção)*; e c) no caso específico, impor a devolução em dobro do indébito*".

O **eminente Ministro João Otávio de Noronha** acompanhou tal posicionamento.

Em voto-vista, o **em. Ministro Luis Felipe Salomão** concluiu, no caso concreto, pelo **provimento dos embargos de divergência**. No tocante à matéria de direito em debate,

considerou haver apenas divergência aparente entre os entendimentos das Turmas das Primeira e Segunda Seções, e, com base nisso, trouxe fundamentação diversa para solucionar a controvérsia, consubstanciada nas seguintes premissas:

> *"**(i)** a sanção civil de devolução em dobro, encartada no parágrafo único do artigo 42 do CDC, revela-se cabida **quando a cobrança indevida consubstanciar má-fé**, compreendida esta como **conduta contrária à boa-fé objetiva**, seja por força de **inobservância do dever anexo de lealdade** - ato deliberado, com intuito fraudulento e malicioso, de prejudicar o consumidor -, **ou do dever anexo de proteção** - ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável;*
> ***(ii)** a **demonstração da omissão ou da recusa do fornecedor** - como, por exemplo, em resposta ao pedido informal e prévio do consumidor apontando a irregularidade da cobrança -, **será indício suficiente** para embasar a pretensão de repetição em dobro;*
> ***(iii) caberá ao fornecedor**, na contestação ou na fase instrutória do processo, **demonstrar que não atuara em contrariedade à boa-fé objetiva**, isto é, que não agira de forma **desleal ou descuidada**, pois o **engano** cometido era, sim, **justificável**; e*
> ***(iv) se houver divergência jurisprudencial em relação ao objeto da cobrança indevida ou caso a cláusula contratual em que se baseie for posteriormente declarada nula**, configura-se hipótese de **engano justificável**, excludente apta a afastar a incidência da sanção civil de repetição em dobro do indébito.*" (grifou-se)

Ao final, propôs "*a seguinte **tese** objetiva: **a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, somente se revela cabível quando a cobrança indevida consubstanciar, concretamente, conduta contrária à boa-fé objetiva, seja por força de inobservância do dever anexo de lealdade - ato deliberado, com intuito fraudulento e malicioso, de prejudicar o consumidor -, ou do dever anexo de proteção/cuidado - ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável."***

Após ouvir atentamente os ricos debates em torno do tema, assim como considerando a inteligente solução intermediária trazida pelo em. **Ministro Luis Felipe Salomão** em seu voto-vista, entendi necessária uma nova apreciação da questão controvertida.

Por essa razão, pedi vista do presente processo (**EREsp 1.413.542/RS**) e de seus correlatos **EAREsps 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS**.

Em novo exame do tema, considero que a solução mais correta a ser adotada é a que nos traz o voto-vista do **Ministro Luis Felipe Salomão**, a qual prestigia a boa lógica natural de

presunção da normalidade das coisas, ou seja, o **primado da boa-fé**.

Lembro que o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor tem a seguinte redação:

> *Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.*
> *Parágrafo único.* ***O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,*** *acrescido de correção monetária e juros legais,* ***salvo hipótese de engano justificável****.*

Do que se extrai da leitura do dispositivo grifado, é correto reconhecer que não traz, em sua literalidade, a exigência da comprovação da "má-fé", tampouco de "culpa" do fornecedor, para a caracterização do direito à devolução em dobro da quantia paga em excesso.

Não obstante essa primeira constatação, é certo também que o Direito - e o próprio Código de Defesa do Consumidor como expressão deste -, não se presta a proporcionar desequilíbrio e insegurança nas relações jurídicas, permitindo e patrocinando transferências de patrimônio entre contratantes, sem causa proporcional que a justifique, sem razoabilidade.

Certamente por isso, no parágrafo único do art. 42 do CDC, o legislador teve o cuidado de fazer expressa ressalva, contida na parte final do dispositivo, de que, na hipótese de engano justificável, a devolução em dobro não é devida. O engano justificável, no caso, seria do fornecedor-credor, ao cobrar, ainda que indevidamente, determinada quantia.

Quando a cobrança for de quantia efetivamente devida, por óbvio, nada haverá a debater.

Somente a cobrança de quantia indevida, portanto, é que enseja o debate. E como se extrai da norma transcrita, **a cobrança de quantia indevida** pode-se dar de **duas formas**: uma, em razão de **engano injustificável**, caracterizando **culpa ou dolo** do fornecedor, rendendo ensejo à aplicação da **dobra na repetição do indébito**; ou em razão de **engano justificável**, quando será devida a **repetição simples**.

Não se pode olvidar que os dispositivos legais não devem ser interpretados isolada ou literalmente, mas seguindo-se as boas técnicas de hermenêutica, entre as quais a histórica, a sistemática e a teleológica.

Nesse sentido, é importante destacar que **a relação de consumo** da qual ora se trata **é também uma relação contratual**, e, como tal, fundada na premissa de que vigora entre as partes contraentes o **Princípio da Boa-fé**, sobre o qual **JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO** oferece a seguinte lição:

> *O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 4º, inciso III, contempla expressamente o* ***princípio da boa-fé nas relações de consumo****, como instrumento fundamental nas relações entre consumidores e fornecedores.*
> *É, por conseguinte, um dever de conduta, e, fundamentalmente, um princípio orientador do comportamento que cada parte deve adotar.*
> *(...)*
> *Isso significa que "as pessoas devem adotar um comportamento leal em toda a fase prévia à constituição de tais relações (diligência* in contrahendo*); e que devem também se comportar lealmente no desenvolvimento das relações jurídicas já constituídas entre eles. Este dever de comportar-se segundo a boa-fé se projeta a sua vez nas direções em que se diversificam todas as relações jurídicas: direitos e deveres.* ***Os direitos devem exercitar-se de boa-fé; as obrigações devem exercitar-se de boa fé****".*
> (*in* Direito do Consumidor: fundamentos doutrinários e visão jurisprudencial. 4ª ed., 2009. Lumen Juris, Rio de Janeiro, p. 14/15).

Grifou-se o período final da transcrição acima, uma vez que a cobrança de determinada quantia pelo fornecedor, mesmo quando indevida, deve ser vista, *a priori*, como o exercício de um direito ou de um pretenso direito **vislumbrado de boa-fé** sob a ótica de um dos contratantes, caracterizando, normalmente, quando muito, um "engano justificável". Somente excepcionalmente ocorrerá ***conduta contrária à boa-fé objetiva,*** quando o valor cobrado não tiver respaldo algum (mínimo mesmo) na relação contratual vigente entre o fornecedor e o consumidor, sendo fruto de má-fé ou de engano injustificável.

Noutras palavras, não se pode presumir que, em regra, o fornecedor deliberadamente conceba formas de cobrança de quantias que sabe não amparadas pela relação contratual, com a intenção de obter vantagem indevida sobre o consumidor, violando o contratado e a própria legislação consumerista protetiva.

Afinal, é noção consolidada no Direito a de que *a boa-fé presume-se (assim como a normalidade das coisas), a má-fé prova-se (assim como a anormalidade das coisas).*

Esta Corte Especial tem decidido nesse sentido inúmeras vezes, conforme se exemplifica com o acórdão abaixo:

> *PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC.*
> *1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução,*

ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. ***A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova****.*
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.
2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.
2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.
(REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ acórdão **Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1º/12/2014)

Feitas essas ponderações, considera-se que, para a aplicação da sanção civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de ***conduta contrária à boa-fé objetiva*** para justificar a reprimenda civil de imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Para tanto, deve ser considerada má-fé, tal como explicitado no voto-vista do eminente **Ministro Luis Felipe Salomão**, a conduta contrária à boa-fé objetiva, "*seja por força de* ***inobservância do dever anexo de lealdade*** *- ato deliberado, com intuito fraudulento e malicioso, de prejudicar o consumidor -,* ***ou do dever anexo de proteção*** *- ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável*".

Ademais, é importante salientar, na linha daquele voto-vista, que "*caberá ao fornecedor, na contestação ou na fase instrutória do processo, demonstrar que não atuara em contrariedade à boa-fé objetiva, isto é, que não agira de forma desleal ou descuidada, pois o engano cometido era, sim, justificável*".

Na hipótese em apreço, embora o acórdão embargado, da colenda Quarta Turma, tenha decidido a controvérsia em conformidade com a orientação acima exposta, exigindo a comprovação da má-fé para a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo

consumidor na cobrança indevida de serviços públicos concedidos (CDC, art. 42, parágrafo único), não deu a solução mais adequada ao caso concreto.

Na análise das premissas fático-probatórias já delineadas pela Corte de origem, observa-se que a cobrança indevida derivou da não contratação de um determinado serviço, posteriormente cobrado da consumidora pela empresa de telefonia. Ademais, o consumidor efetuou diversas reclamações perante o *call center* da empresa, relativamente à cobrança indevida, não obtendo êxito.

Eis o que consta do acórdão proferido na origem, *in verbis*:

> *De maneira geral, em relação aos danos morais em* ***casos como o que aqui se apresenta, de cobrança indevida de valores referentes a serviços não solicitados****, gerando inclusive inscrição negativa e, muitas vezes, bloqueio do serviço, tenho que o abalo psicológico sofrido pela parte autora é evidente. Todavia, a situação, no caso concreto, é atípica e não se enquadra nestes casos, havendo necessidade de prova acerca dos eventuais danos morais ocorridos.*
>
> ***No caso concreto, apesar de não ter havido a inscrição indevida e nem mesmo o bloqueio dos serviços, a autora trouxe aos autos diversos números de protocolos de reclamações realizadas por meio de cail center (fl. 08), para tentar solucionar o ocorrido, sem obtê-la.***
>
> (...)
>
> *4. Repetição de indébito em dobro. Art. 42. § único, do CDC:*
>
> *Não há dúvidas de que a relação estabelecida entre a operadora de telefonia e a cliente autora é de consumo, devendo ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, con forme já exposto acima. Por essa razão, não há como cogitar reconhecer a não aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que dita:*
>
> (...)
>
> *A lei é clara e não deixa qualquer dúvida.*
>
> *Obviamente que a aplicação desta norma exige que exista relação de consumo e que efetivamente tenha ocorrido o pagamento pelo consumidor, bem como não se trate de hipótese de engano justificável. Cumpre destacar que, em se tratando de relação consumerista, não há exigência alguma no sentido de que o consumidor comprove existência de má-fé por parte do fornecedor do serviço ao efetuar a cobrança indevida.*

Desse modo, houve por parte da fornecedora recebimento de valores cobrados indevidamente do consumidor, em conduta contrária à boa-fé objetiva, por violação do dever anexo de proteção. Por essa razão, na hipótese, não há como afastar o direito à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Diante do exposto, peço vênia para **acompanhar o voto-vista divergente**

apresentado pelo eminente **Ministro Luis Felipe Salomão**, e, no caso concreto, delibero no sentido de dar provimento aos embargos de divergência.

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2013/0355826-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EREsp 1.413.542 / RS**

Números Origem: 00024664120118210124 00382183920138217000 11100012910 12111794201382170000 12411100012910 24664120118210124 382183920138217000 70052756772 70053135935 70053964904

PAUTA: 20/11/2019 JULGADO: 04/12/2019

Relatora
Exma. Sra. Ministra **MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro : **BENEDITO GONÇALVES**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE	:	PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539 ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO	:	BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS	:	TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227 CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494 ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por Dano Moral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Raul Araújo acompanhando o voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, foi suspenso o julgamento.

Aguardam os Srs. Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Felix Fischer e Humberto Martins.

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho e Paulo de Tarso Sanseverino.

Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Licenciado o Sr. Ministro Felix Fischer.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2013/0355826-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EREsp 1.413.542 / RS**

Números Origem: 00024664120118210124 00382183920138217000 11100012910 12111794201382170000 12411100012910 24664120118210124 382183920138217000 70052756772 70053135935 70053964904

PAUTA: 18/12/2019 JULGADO: 18/12/2019

Relatora
Exma. Sra. Ministra **MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro : **BENEDITO GONÇALVES**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE	:	PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539 ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO	:	BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS	:	TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227 CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494 ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por Dano Moral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2013/0355826-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EREsp 1.413.542 / RS**

Números Origem: 00024664120118210124 00382183920138217000 11100012910 12111794201382170000 12411100012910 24664120118210124 382183920138217000 70052756772 70053135935 70053964904

PAUTA: 04/03/2020 JULGADO: 04/03/2020

Relatora
Exma. Sra. Ministra **MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro : **BENEDITO GONÇALVES**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE	:	PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539
		ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO	:	BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS	:	TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227
		CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494
		ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por Dano Moral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento para a próxima sessão.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2013/0355826-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EREsp 1.413.542 / RS**

Números Origem: 00024664120118210124 00382183920138217000 11100012910 1211179420138217000 12411100012910 24664120118210124 382183920138217000 70052756772 70053135935 70053964904

PAUTA: 07/10/2020 JULGADO: 07/10/2020

Relatora
Exma. Sra. Ministra **MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro : **BENEDITO GONÇALVES**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE	:	PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539 ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO	:	BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS	:	TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227 CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494 ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por Dano Moral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9)

ADITAMENTO AO VOTO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA:

Caros pares, gostaria de fazer uma brevíssima síntese acerca da controvérsia.

Em 2015, trouxe a esta Corte os primeiros embargos de divergência (EAREsp 600.663/RS) com o objetivo de pacificar a questão relativa à aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, isto é, definir quais os critérios a serem considerados para a repetição do indébito em dobro.

Isso, porque os paradigmas proferidos pelas Turmas que compõem a Primeira Seção firmaram entendimento no sentido de que basta a configuração da culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo consumidor, sendo certo que esses julgados se referiam a serviços públicos concedidos, circunstância que não impede a configuração do dissenso, que deve ser analisado sob o enfoque da relação de consumo.

Do outro lado, as Turmas de Direito Privado exigem a comprovação da má-fé do credor na cobrança indevida para que se determine a devolução em dobro.

Ao proferir meu voto, destaquei que a letra do CDC não faz qualquer menção à necessidade de comprovação de má-fé do credor. A única possibilidade de escusa é a ocorrência de "engano justificável". Escusa essa, que deve ser demonstrada pelo fornecedor, não, pelo consumidor, que é parte vulnerável da relação.

Ao ensejo, gostaria de ajustar meu voto no ponto em que consignado que "não é necessária a comprovação da má-fé do credor, *basta a culpa"*. Na verdade, não há falar em culpa, tampouco em dolo. Mas, sim, em engano justificável que, como muito bem asseverado pela Min. Nancy em seu voto, "consiste em excludente de culpabilidade no que toca ao pleito da devolução em dobro, sendo que nas hipóteses em que houver essa justificativa caberá apenas a devolução simples dos valores indevidamente cobrados".

Desse modo, reafirmo meu posicionamento no sentido de que os requisitos legais para a repetição em dobro na relação de consumo são a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável do fornecedor. A exigência de indícios mínimos de má-fé objetiva do fornecedor é requisito não previsto na lei e, a toda evidência, prejudica a parte frágil da relação.

Outrossim, conforme já registrado oralmente em sessão de julgamento, não vejo razão para modulação dos efeitos.

Com esses esclarecimentos, mantenho meu posicionamento quanto ao tema.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9)

VOTO-VOGAL

O EXMO. SR. MINISTRO OG FERNANDES: Trata-se de embargos de divergência interpostos por Pedro Lugoch contra acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte assim ementado:

> AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
> 1. A repetição de indébito em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor não prescinde da prova de má-fé do credor. Incidência da Súmula 83/STJ.
> 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

Alega o embargante dissídio jurisprudencial no tocante ao tema relativo à repetição do indébito em dobro, disciplinado no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, apontando como paradigmas julgados da Primeira e Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 371.431/MS e AgRg no AREsp 262.212/RS, respectivamente).

Afirma que há divergência quanto à necessidade de comprovação da má-fé na cobrança indevida para que a devolução se dê em dobro.

A eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, confirmando o entendimento já externado em outras oportunidades, a exemplo do Earesp nº 600.663/SP, também em julgamento na sessão de hoje, votou no sentido de que não se mostra necessária a comprovação de má-fé do credor para que haja restituição em dobro de parcelas pagas indevidamente. Privilegia, no ponto, a compreensão que vem sendo adotada nas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte.

Dessa forma, não tenho dúvidas em acompanhar a ilustre Relatora, com os acréscimos e ponderações que fiz por ocasião do Earesp nº 676.608/RS, do qual sou relator, e no qual assentei a compreensão de que: "*1) a restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a*

cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva; 2) a repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, deve seguir a norma geral do lapso prescricional (10 anos - art. 205, Código Civil), a exemplo do que decidido e sumulado (Súmula 412/STJ) no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de indébito de tarifas de água e esgoto.".

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência para negar provimento ao recurso especial da empresa de telefonia.

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2013/0355826-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EREsp 1.413.542 / RS**

Números Origem: 00024664120118210124 00382183920138217000 11100012910 12111794201382170000 12411100012910 24664120118210124 382183920138217000 70052756772 70053135935 70053964904

PAUTA: 07/10/2020 JULGADO: 21/10/2020

Relatora
Exma. Sra. Ministra **MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**

Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro **HERMAN BENJAMIN**

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro : **BENEDITO GONÇALVES**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE	:	PEDRO LUGOCH
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI E OUTRO(S) - RS066539 ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424
EMBARGADO	:	BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS	:	TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH E OUTRO(S) - RS008227 CAROLINA SOARES MARTINS CORRÊA E OUTRO(S) - RS075494 ANA MARIA ARÊAS E OUTRO(S) - RS077184A

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por Dano Moral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto do Sr. Ministro Herman Benjamin conhecendo dos embargos de divergência e dando-lhes provimento, com modulação dos efeitos, no que foi acompanhado pelos Srs. Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo e Humberto Martins, e a ratificação dos votos das Sras. Ministras

Relatora e Nancy Andrighi, a Corte Especial, por maioria, conheceu dos embargos de divergência e deu-lhes provimento, com modulação dos efeitos.

Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Herman Benjamin. Vencidas as Sras. Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura que conheciam dos embargos e davam-lhes provimento, mas por outro fundamento e sem modulação dos efeitos.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, João Otávio de Noronha e Napoleão Nunes Maia Filho.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.